



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Internationales Steuerrecht 02

Das Recht der DBA

DBA Verhandlungsgrundlage

Treaty Override

62

Verfasser:

Dr. Tobias Hagemann

Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
1.	Funktion und Wesen von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)	1
2.	Verhältnis von DBA zu den nationalen Steuergesetzen	2
3.	Treaty Override im deutschen Steuerrecht	2
4.	Prüfschema in DBA-Fällen	2
II.	AUFBAU VON DBA	3
III.	PERSÖNLICHE UND SACHLICHE ANWENDBARKEIT VON DBA	5
1.	Persönlicher Anwendungsbereich von DBA	5
2.	Sachlicher Anwendungsbereich von DBA	7
IV.	DIE ABKOMMENSRECHTLICHEN EINKUNFTSARTEN (VERTEILUNGSNORMEN)	7
1.	Vorbemerkung	7
2.	„Ansässigkeitsstaat“, „anderer Staat“ und Doppelansässigkeit	8
3.	Darstellung der einzelnen Einkunftsarten	10
3.1	Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen (Art. 6 DE-VHG)	10
3.2	Unternehmensgewinne (Art. 7 DE-VHG)	10
3.3	Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und Luftfahrt (Art. 8 DE-VHG)	12
3.4	Einkünftekorrektur (Art. 9 DE-VHG)	13
3.5	Dividenden (Art. 10 DE-VHG)	13
3.6	Zinsen und Lizenzgebühren (Art. 11 und Art. 12 DE-VHG)	15
3.7	Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen (Art. 13 DE-VHG)	16
3.8	Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (Art. 14 DE-VHG)	17
3.9	Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen (Art. 15 DE-VHG)	18
3.10	Künstler und Sportler (Art. 16 DE-VHG)	19
3.11	Ruhegehälter, Renten und ähnliche Zahlungen (Art. 17 DE-VHG)	19
3.12	Öffentlicher Dienst (Art. 18 DE-VHG)	20
3.13	Gastprofessoren, Lehrer und Studenten (Art. 19 DE-VHG)	21
3.14	Andere Einkünfte (Art. 20 DE-VHG)	22
3.15	Vermögen (Art. 21 DE-VHG)	23
V.	VERMEIDUNG VON DOPPELBESTEUERUNG	23
1.	Notwendigkeit der Anwendung des Methodenartikels	23
2.	Grundfall: Freistellung unter Progressionsvorbehalt	24
3.	Anrechnungsmethode	25
VI.	PROTOKOLL	27



VII.	TREATY OVERRIDE	27
1.	Arten von Treaty Override	27
2.	Darstellung ausgewählter Treaty Override anhand von Beispielsfällen	29
VIII.	ÜBUNGSFÄLLE	35
1.	Übungsfall 1	35
2.	Übungsfall 2	38
3.	Übungsfall 3	40

I. EINFÜHRUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Internationales Steuerrecht 02 – Überblick – v13104



LERNZIEL

Nach der Durcharbeitung dieses Moduls können Sie insbesondere:

- *Die Anwendbarkeit von DBA bestimmen,*
- *Einkünfte innerhalb der abkommensrechtlichen Einkunftsarten zuordnen,*
- *Entscheiden, ob im Einzelfall das DBA oder ein nationaler Treaty Override vorgeht.*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – v10856

1. Funktion und Wesen von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)

Wie in Lehrbrief IStR 01 gelernt, besteuert bei grenzüberschreitenden Sachverhalten regelmäßig ein Staat auf Basis der unbeschränkten Steuerpflicht (Welteinkommensprinzip) und der andere Staat auf Basis der beschränkten Steuerpflicht (Territorialitätsprinzip). Aus diesem Doppelzugriff entsteht das Risiko einer Doppelbesteuerung. Wenngleich das nationale Recht (insbesondere § 34c EStG) Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem vorsieht, sind die Staaten dazu übergegangen, weitergehende Maßnahmen zu ergreifen: Sie schließen auf völkerrechtlicher Grundlage Verträge, die der Vermeidung der Doppelbesteuerung dienen – sog. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Im Rahmen dieser Abkommen verständigen sich die Staaten insbesondere darauf, welcher Sachverhalt in welchem Umfang von welchem der beteiligten Staaten besteuert werden darf und wie der Ansässigkeitsstaat die Doppelbesteuerung vermeidet, wenn der andere Staat im Rahmen des Territorialitätsprinzips besteuern darf. Diese Abkommen sind regelmäßig (nur) auf bilateraler Basis geschlossen, also nur zwischen jeweils zwei Staaten. Sind an einem Sachverhalt mehr als zwei Staaten beteiligt (Mehrstaatensachverhalt), kann es leicht zur Anwendung von mehr als einem DBA auf den gleichen Sachverhalt kommen.

Um sich die Wirkung von DBA zu verdeutlichen, hat *Klaus Vogel* einst von einer „Lochschablone“ gesprochen, die über die Besteuerungsansprüche des nationalen Rechts gelegt wird. Dies bedeutet: Das DBA-Recht wird nachgelagert geprüft. Zunächst sind die Besteuerungsansprüche der Staaten nach deren nationalem Recht festzustellen. Anschließend wird das DBA hinzugezogen und geprüft, ob dieses die nationalen Besteuerungsansprüche beschränkt. Nur soweit Letzteres nicht der Fall ist, darf ein Staat dann besteuern (vorbehaltlich eines Treaty Override). Darin erschöpft sich die Funktion des DBA-Rechts, das deshalb auch als „Schrankenrecht“ bezeichnet wird.



HINWEIS

Abkommensrecht ist „Schrankenrecht“, was bedeutet, ein DBA kann nationale Besteuerungsansprüche ausschließlich beschränken. Dagegen ist es nicht denkbar, dass ein Vorfall zwar nach nationalem Recht nicht besteuert wird, das DBA dann aber einen Besteuerungsanspruch begründet. Die Wirkung von DBA ist also stets einseitig, nämlich beschränkend. Im Rahmen einer Prüfung bedeutet dies: Wenn in einem Sachverhalt bereits nach nationalem Recht keine Steuerpflicht besteht, muss ein DBA nicht mehr geprüft werden.

2. Verhältnis von DBA zu den nationalen Steuergesetzen

DBA sind völkerrechtliche Verträge. Sie werden von Vertretern der Bundesregierung mit den Vertretern anderer Staaten ausgehandelt. Da die Bundesregierung als Exekutive jedoch nicht zur Gesetzgebung befugt ist, bedarf es der Zustimmung durch das Parlament (Art. 59 Abs. 2 GG), damit ein DBA zum Gesetz wird. Durch den Zustimmungsbefehl wird das DBA zu einem einfachen deutschen Steuergesetz. Es steht im Rang somit den anderen Steuergesetzen gleich. DBA gehen dem EStG oder KStG folglich – anders als die Verfassung oder das Unionsrecht – nicht bereits eines höheren Ranges wegen vor.

Gleichrangige Gesetzesvorschriften können in Kollision zueinander treten, wobei sich in diesen Fällen die Frage stellt, wie eine solche Normenkollision aufzulösen ist. Die Antwort findet der Rechtsanwender in § 2 Abs. 1 AO: „Verträge mit anderen Staaten im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 des Grundgesetzes über die Besteuerung gehen, soweit sie unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, den Steuergesetzen vor“. Mit dieser Vorschrift hat sich der Gesetzgeber jedoch nicht zum allgemeinen Vorrang des Völkerrechts bekannt, sondern lediglich klargestellt, dass in einem grenzüberschreitenden Sachverhalt das jeweilige DBA im Ausgangspunkt vorgehen soll. Ohne diesen grundsätzlichen Vorrang könnten DBA ihren Zweck als „Schrankenrecht“ zur Vermeidung von Doppelbesteuerung nicht erfüllen.

3. Treaty Override im deutschen Steuerrecht

Diejenigen unter Ihnen, die mit dem Begriff des „Treaty Override“ vertraut sind, werden sich an dieser Stelle fragen, ob die letzte Aussage in dieser Allgemeinheit zutrifft. Dies tut sie zwar, weil § 2 Abs. 1 AO einen vor die Klammer gezogenen Vorbehalt zugunsten der DBA enthält, der grundsätzlich für sämtliche Steuergesetze gilt. Allerdings sieht das in der deutschen Verfassung verbürgte Demokratieprinzip die zwingende Möglichkeit für den Gesetzgebers vor, frühere gesetzgeberische Entscheidungen revidieren zu können. Damit einher geht die Möglichkeit, punktuell von dem DBA-Vorrang gemäß § 2 Abs. 1 AO abzuweichen und einzelne nationale Vorschriften zu erlassen, die DBA (Englisch: „(tax) treaties“) überschreiben („override“). Grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet dies nicht (BVerfG, Beschl. v. 15.12.2015 – 2 BvL 1/12). Solche nationalen Vorschriften finden sich vermehrt im deutschen Internationalen Steuerrecht, weshalb Ihnen der zweite Teil dieses Moduls gewidmet ist.

4. Prüfschema in DBA-Fällen

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich folgendes Prüfschema in grenzüberschreitenden Sachverhalten im Verhältnis zu DBA-Staaten:

1. Prüfung der Besteuerung (dem Grunde und der Höhe nach) allein nach den Vorschriften des innerstaatlichen Rechts,
2. Prüfung, ob ein bestehender Besteuerungsanspruch durch das DBA eingeschränkt wird,
3. Prüfung, ob für den Einzelfall ein Treaty Override besteht, der diese Beschränkung (teilweise) wieder rückgängig macht.

Der erste Schritt betrifft reines Deutsches Steuerrecht und wird daher vorliegend nicht besprochen, sondern war Gegenstand des Moduls IStR 01. Dieses Modul beschränkt sich darauf, Ihnen zunächst die Anwendung des DBA darzustellen und anschließend wichtige Treaty Override vorzustellen (Schritte 2 und 3).



HINWEIS

In den Prüfungslösungen der vergangenen Jahre ist das Vorgehen uneinheitlich. Teilweise wird in den Musterlösungen unserem Schema entsprechend zunächst die Besteuerung nach nationalem Recht dem Grunde und der Höhe nach geprüft, erst danach das DBA. In den Lösungen anderer Jahre wird dagegen zunächst die nationale Einkunftsart festgelegt, dann im DBA geprüft, ob besteuert werden darf und erst danach (falls nötig) die Einkünfte berechnet. Wenn Sie sich stets an unser Schema halten, werden Sie gleichwohl in beiden Fällen die volle Punktzahl erzielen können.

II. AUFBAU VON DBA

Die OECD hat im Jahre 1963 erstmals ein sog. Musterabkommen (OECD-MA) als Vorlage für die DBA zwischen den verschiedenen Staaten veröffentlicht, welches seither mehrfach überarbeitet wurde. Im August 2013 hat das deutsche BMF ebenfalls ein „Musterabkommen“ für deutsche DBA veröffentlicht, das als deutsche Verhandlungsgrundlage für DBA (DE-VHG) bezeichnet wird. In diesem Modul werden wir Ihnen diese DE-VHG inhaltlich vorstellen, nicht das OECD-MA, weil die Verhandlungsgrundlage inhaltlich näher an den deutschen DBA gelegen ist, welche Ihnen im Prüfungsfall zur Verfügung gestellt werden können. Die DE-VHG finden Sie auf der Homepage des BMF.

Die DE-VHG hat – ebenso wie das OECD-MA und der Großteil der deutschen DBA – folgenden Aufbau:

- Art. 1 und Art. 2 regeln den persönlichen bzw. den sachlichen Anwendungsbereich des Abkommens. Eine vollständige und systematische Aufgabenlösung beginnt stets mit diesen Artikeln!
- Art. 3, Art. 4 und Art. 5 enthalten Begriffsbestimmungen, also Definitionen, die für die Anwendung des DBA – sowohl im Anwendungsbereich als auch bei den Verteilungsnormen sowie beim Methodenartikel – von Bedeutung sind. Einige dieser Begriffsbestimmungen sind für Ihre Lösung unerlässlich, mit anderen werden Sie sich vermutlich nie befassen. Da diese Begriffsbestimmungen keine Rechtsfolgen anordnen, sondern lediglich Definitionen enthalten, werden sie nachfolgend im Rahmen der DBA-Vorschriften, für deren Auslegung sie relevant sind, besprochen.
- Art. 6 bis 20 regeln die Besteuerung des Einkommens, Art. 21 sodann die Besteuerung des Vermögens. Die Gesamtheit dieser Normen nennt man auch „Verteilungsnormen“, weil es ihre Aufgabe ist, die Besteuerungsrechte zwischen den beiden Vertragsstaaten aufzuteilen. Tatsächlich sprechen die Verteilungsnormen aber i. d. R. vorrangig den Nicht-Ansässigkeitsstaat (also einen Quellenstaat) an und beschränken dessen Besteuerungsrecht (vollständig, teilweise oder gar nicht – was einer Zuweisung des Besteuerungsrechts gleichkommt).
- Auf die Verteilungsnormen, die sich vorrangig an den Quellenstaat richten, folgt stets ein Methodenartikel, der festlegt, wie die Doppelbesteuerung zu vermeiden ist. Denn Ihnen muss klar sein: Wenn eine Verteilungsnorm dem Quellenstaat sagt, er darf – neben dem vom Verteilungsartikel regelmäßig nicht angesprochenen Ansässigkeitsstaat „auch“ – besteuern, dann besteht weiterhin das Problem der Doppelbesteuerung. Der Ansässigkeitsstaat muss dann die im Quellenstaat besteuerten Einkünfte freistellen oder die ausländische Steuer anrechnen (Art. 22 DE-VHG). Beachten Sie bitte: Der Methodenartikel richtet sich ausschließlich an den Ansässigkeitsstaat.



- Nach dem Methodenartikel enthalten DBA regelmäßig besondere Bestimmungen und Schlussbestimmungen (Art. 23 bis 32 DE-VHG). In diesen Vorschriften finden sich nur wenige Bezüge zur materiellen Besteuerung, weshalb diese Klauseln auch für eine Prüfung von nachrangiger Bedeutung sind.
- Die meisten deutschen DBA enthalten ebenfalls ein Protokoll. Dieses ist – eine entsprechende Klausel finden Sie regelmäßig im DBA selbst (Art. 30 DE-VHG) – Bestandteil des DBA und damit den DBA-Regelungen gleichrangig. Da das Protokoll aber gewissermaßen als „Anhang“ zu DBA steht, wird es oftmals übersehen. Merken Sie sich daher bitte stets, einen (oftmals nur kurzen) Blick ins Protokoll zu werfen, um zu prüfen, ob sich dort für ihren Sachverhalt wesentliche Ausführungen finden.

Bevor im Folgenden die einzelnen Gliederungspunkte besprochen werden, möchten wir darauf hinweisen, dass fast alle deutsche DBA diesem Aufbau folgen (eine der wenigen Ausnahmen ist z. B. das DBA Frankreich). Ganz gleich, welchen Aufbau DBA aber haben, gehen Sie bitte immer nach der folgenden Prüfreihefolge vor:

Inbound-Fall:

1. Prüfen Sie zunächst den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des DBA unter Berücksichtigung der Begriffsbestimmungen.
2. Prüfen Sie anschließend die Verteilungsnormen des DBA unter Berücksichtigung der Begriffsbestimmungen. Werfen Sie sodann einen Blick ins Protokoll und sichern Sie dadurch Ihr Ergebnis ab. Wenn Sie einen Inbound-Fall prüfen (weil eine nur beschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht), dann ist Ihre DBA-Prüfung hiermit abgeschlossen, denn nach Prüfung der Verteilungsnormen wissen Sie, ob bzw. inwieweit der deutsche Besteuerungsanspruch im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht aufrechterhalten wird. Gleiches gilt, wenn zwar nach nationalem Recht eine unbeschränkte Steuerpflicht besteht, Deutschland aber wegen Art. 4 Abs. 2 des DBA nicht als Ansässigkeitsstaat gilt.
3. Prüfen Sie abschließend nochmals das innerstaatliche Steuerrecht, denn Deutschland könnte sich über das DBA einseitig hinwegsetzen (Treaty Override).

Outbound-Fall:

1. Prüfen Sie zunächst den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich unter Berücksichtigung der Begriffsbestimmungen.
2. Prüfen Sie anschließend die Verteilungsnormen des DBA unter Berücksichtigung der Begriffsbestimmungen. Werfen Sie sodann einen Blick ins Protokoll und sichern Sie dadurch Ihr Ergebnis ab.
3. Im Outbound-Sachverhalt (d. h. unbeschränkte Steuerpflicht und (!) DBA-Ansässigkeit in Deutschland) müssen Sie nun – sofern nicht eine Verteilungsnorm mit abschließender Rechtsfolge (d. h. mit ausschließlicher Zuweisung des Besteuerungsrechts zu einem Staat) vorliegt – in den Methodenartikel schauen und prüfen, wie Deutschland die Doppelbesteuerung vermeidet. Verproben Sie bitte auch dieses Ergebnis durch einen Blick ins Protokoll!
4. Auch im Outbound-Fall ist auf die Möglichkeit bestehender Treaty Override hinzuweisen, die es anschließend zu berücksichtigen gilt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Aufbau von DBA – v10858

III. PERSÖNLICHE UND SACHLICHE ANWENDBARKEIT VON DBA

1. Persönlicher Anwendungsbereich von DBA

Der „Einstieg“ in die DBA-Prüfung ist simpel und dürfte im Einzelfall kaum variieren (vorbehaltlich der Zitation der Vorschriften in den DBA, die Sie natürlich im Einzelfall suchen und identifizieren müssen). Bitte führen Sie diesen Schritt stets durch! Wir können Ihnen nicht garantieren, dass es hierfür in einer Prüfung Punkte gibt, wir garantieren Ihnen aber, dass Sie – wenn es Punkte gibt – diese mit unserem „Einstieg“ stets holen!

Art. 1 OECD-MA knüpft den persönlichen Geltungsbereich des Abkommens an eine (in einem oder in beiden Staaten) „ansässige Person“. Es ist für die persönliche Abkommensberechtigung folglich unbeachtlich, wenn eine Person in beiden Vertragsstaaten eines DBA ansässig ist. Für die Bestimmung des persönlichen Geltungsbereichs benötigen wir erstmals die Begriffsbestimmungen: Nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG umfasst der Begriff „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften (gemeint sind Kapitalgesellschaften, vgl. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 DE-VHG) oder andere Personenvereinigungen, also auch Personengesellschaften! Die Frage, wann eine Person ansässig ist, wird in Art. 4 DE-VHG beantwortet: Nach Art. 4 Abs. 1 DE-VHG ist eine Person in einem Staat ansässig, wenn sie dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. Nicht genügend ist dagegen eine lediglich auf (inländischen) Einkunftsquellen beruhende Steuerpflicht. Dies sollte Sie erkennen lassen, dass die unbeschränkte Steuerpflicht mit dem Welteinkommen zur abkommensrechtlichen Ansässigkeit führt, die beschränkte Steuerpflicht nur inländischer Einkünfte dagegen nicht.

▶ **Beispiel 1:**

Die natürliche Person Barbara Schöneberg (BS) hat ihren Wohnsitz in Deutschland. Ihre Einkommensteuer entrichtet sie im Rahmen der unbeschränkten Steuerpflicht. Wie sieht eine Musterlösung den Geltungsbereich der DBA betreffend aus und welche DBA sind überhaupt auf Barbara anwendbar?

▶ **Lösung:**

BS ist als natürliche Person „Person“ i. S. d. Abkommens (Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG). Sie unterliegt in Deutschland aufgrund ihres Wohnsitzes der unbeschränkten Steuerpflicht (§ 1 Abs. 1 Satz 1 EStG, § 8 AO). Somit ist sie nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 DE-VHG in Deutschland ansässig. Als in Deutschland ansässige Person ist das DBA auf BS persönlich anwendbar (Art. 1 DE-VHG). Die Einkommensteuer wird auch sachlich vom DBA erfasst (Art. 2 Abs. 1 DE-VHG, vgl. auch die Aufzählung in Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a DE-VHG). Somit ist das DBA auch sachlich anwendbar. Da der Geltungsbereich in allen DBA nahezu identisch ausgestaltet ist, bedeutet dies: BS kann sich auf alle deutschen DBA berufen und fällt unter deren Abkommensschutz. Benötigen tut sie dies nicht, sondern i. d. R. nur im Verhältnis zu Staaten, aus denen sie Einkünfte erzielt.

▶ **Beispiel 2:**

(Abwandlung zum vorigen Beispiel)

Was ändert sich an der Lösung, wenn nicht die natürliche Person, sondern die Barbara Schöneberg GmbH oder KG jeweils mit Sitz im Inland betroffen ist?

▶ **Lösung:**

Auch Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften sind „Person“ i. S. d. Abkommens (Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG). Eine Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung (§ 10 AO) oder Sitz (§ 11 AO) in Deutschland unterliegt in Deutschland auch der unbeschränkten Steuerpflicht (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG) und ist damit in Deutschland ansässig. Der Sitz einer Kapitalgesellschaft ist zwar in Art. 4 Abs. 1 Satz 1 DE-VHG nicht explizit genannt, stellt aber ein „anderes ähnliches Merkmal“ dar!



Bei der KG sähe es anders aus. Zwar handelt es sich um eine „Person“, aber unterliegt diese in Deutschland der Besteuerung? Ja und Nein: Wir wissen, dass eine KG weder einkommen- noch körperschaftsteuerpflichtig ist. Allerdings ist eine gewerbliche KG selbst Schuldner der Gewerbesteuer (§ 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG).

Die Gewerbesteuer ist auch eine sachlich vom DBA erfasste Steuer (Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. c DE-VHG). Sie basiert allerdings auf dem Territorialitätsprinzip und knüpft an eine inländische Betriebsstätte als inländische Einkunftsquelle an (§ 2 Abs. 1 GewStG). Gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 2 DE-VHG führt eine auf inländischen Einkunftsquellen basierende Steuerpflicht jedoch gerade nicht zur Ansässigkeit. Die KG ist deshalb nicht selbst persönlich abkommensberechtigt, ggf. aber deren steuerpflichtige Gesellschafter! Würde die KG nach § 1a KStG zur Körperschaftsteuer optieren, wäre sie selbst körperschaftsteuerpflichtig und somit auch ansässig i. S. d. DBA.



HINWEIS

Viele deutsche DBA enthalten Ansässigkeitsfiktionen für Personengesellschaften (so z. B. in Art. 4 Abs. 4 DBA-Polen). Diese Fiktionen haben nach der Rechtsprechung des BFH in aller Regel (eine Ausnahme findet sich noch im alten DBA-Portugal) keine Auswirkungen auf die Besteuerung der Gesellschafter der Personengesellschaft, sondern sollen es einer Personengesellschaft im anderen (Quellen-)Staat lediglich ermöglichen, Quellensteuerentlastungen geltend zu machen. Gilt eine Personengesellschaft somit nach einem DBA als ansässig, heißt das nicht, dass sie wie eine GmbH im Rahmen des DBA behandelt wird. Für die Besteuerung des Gesellschafters bleibt die Personengesellschaft „transparent“.

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen: Aus deutscher Sicht ist nur in Deutschland ansässig, wer unbeschränkt einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtig ist. Die Gewerbesteuerpflicht begründet keine Ansässigkeit. Wer allerdings wegen seiner Einkommen- oder Körperschaftsteuerpflicht ansässig ist, genießt den Abkommenschutz auch im Rahmen der Besteuerung des Gewerbeertrags (siehe zum sachlichen Anwendungsbereich unter 2.).



HINWEIS

Wenn Sie sich fragen, was passiert, wenn eine Person in zwei Staaten, die Vertragspartner eines DBA sind, ansässig ist, dann ist diese Frage wichtig, betrifft jedoch eine andere Ebene. Für die Frage der Eröffnung des persönlichen Anwendungsbereichs des DBA ist die Doppelansässigkeit unerheblich, weil das DBA in einem solchen Fall anwendbar ist.

Für die richtige Anwendung des DBA ist die Frage der Doppelansässigkeit freilich+ von entscheidender Bedeutung. Sie wird daher an gegebener Stelle (Abschnitt IV.2) besprochen. Im Rahmen einer Prüfung würden Sie freilich in aller Regel gleich vorab auch diese Frage klären.

Es bleibt noch die Frage, welche Folgen die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 2 EStG) oder die fiktive unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 3 EStG) für die DBA-Ansässigkeit haben. Für die fiktiv unbeschränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 3 EStG ist die Antwort kurz und einfach: Die Steuerpflicht erstreckt sich nach § 1 Abs. 3 EStG nur auf die „inländischen Einkünfte“ und dies ist für die DBA-Ansässigkeit nicht ausreichend, weil eine Besteuerung des Welteinkommens fehlt. Schwieriger zu beantworten ist die Frage der Ansässigkeit in Fällen des § 1 Abs. 2 EStG. Da die Besteuerung in diesen Fällen jedoch mit dem Welteinkommen erfolgt, vertreten renommierte Autoren im Schrifttum die Auffassung, dass die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht die abkommensrechtliche Ansässigkeit begründet.

2. Sachlicher Anwendungsbereich von DBA

Der sachliche Anwendungsbereich ist in Art. 2 DE-VHG normiert. Danach fallen – ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung – „Steuern vom Einkommen und vom Vermögen“ unter das DBA. Voraussetzung ist eine Erhebung für Rechnung eines Vertragsstaats, eines seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften.

Gemäß Art. 2 Abs. 2 DE-VHG gelten als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen alle Steuern, die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs.

Auf Basis dieser Definition gibt Art. 2 Abs. 3 DE-VHG einen Katalog erfasster Steuerarten vor. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sind – einschließlich hierauf erhobener Zuschläge – stets von den deutschen DBA erfasst.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Anwendbarkeit von DBA – v10857

IV. DIE ABKOMMENSRECHTLICHEN EINKUNFTSARTEN (VERTEILUNGSNORMEN)

1. Vorbemerkung

Ist der Geltungsbereich eines Abkommens eröffnet, so widmen wir uns der Suche nach der einschlägigen Einkunftsart. Im Grunde finden wir hierzu einen Katalog an Einkunftsarten, ähnlich wie dies im nationalen Recht der Fall ist. Wir müssen dennoch strikt zwischen dem nationalen Recht und dem Abkommensrecht unterscheiden! Hierfür gibt es verschiedene Gründe.

Zunächst liegt dies im Wesen des Abkommensrechts begründet, welches bilaterales Recht darstellt. DBA bezwecken die Vermeidung von Doppelbesteuerung. Dieses Ziel können sie i. d. R. nur erreichen, wenn beide Staaten das Abkommen gleich anwenden. Kommen die Staaten zu unterschiedlichen Auslegungsergebnissen, so sprechen wir von einem Qualifikationskonflikt, der leicht zu Doppel- (beide Staaten denken, sie dürften besteuern) oder Minderbesteuerungen (beide Staaten denken, sie dürften nicht besteuern) führen kann. Um solche Qualifikationskonflikte zu vermeiden, soll das DBA stets losgelöst vom innerstaatlichen Verständnis angewendet werden. Wir sprechen insoweit von der **abkommensautonomen Auslegung**.

Mit diesem „Grundgerüst“ müssen Sie sich also auf die Suche nach einer – und es gibt stets nur eine einschlägige – Verteilungsnorm machen. Verstehen Sie die abkommensrechtlichen Einkunftsarten als sog. Meta-Ebene, d. h. als eigene Welt, in der die innerstaatlichen Zuordnungsregelungen nicht greifen. Sie können es schon allein deshalb nicht, weil jeder Staat unterschiedliche Konzepte verfolgt.

Ein weiterer Grund für die gebotene Unterscheidung der Einkunftsarten des nationalen Rechts und des DBA liegt in einer grundsätzlich unterschiedlichen Systematik begründet. Im nationalen Recht gilt bekanntermaßen das Subsidiaritätsprinzip, dem zufolge z. B. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 8 EStG) oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 3 EStG) vorrangig den Gewinneinkunftsarten zugeordnet werden, wenn sie im Rahmen eines Unternehmens erzielt werden. Umgekehrt gilt im Abkommensrecht das **Spezialitätsprinzip**: Gehören zu den Unternehmensgewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln des Abkommens gesondert behandelt werden, so kommen diese gesonderten Bestimmungen zur Anwendung (Art. 7 Abs. 4 DE-VHG).



Deshalb sind z. B. die in Form von Zinsen erzielten Sondervergütungen eines Mitunternehmers zwar im nationalen Recht Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG), im Abkommensrecht handelt es sich aber um Zinsen i. S. v. Art. 11 DE-VHG (was wiederum durch § 50d Abs. 10 EStG unilateral überschrieben wird, dazu später).

Verteilungsnormen sind i. d. R. auf eine Beschränkung des Besteuerungsrechts des Quellenstaates ausgerichtet: Dies geschieht, indem festgestellt wird, ob bzw. inwieweit Einkünfte in diesem Quellenstaat besteuert werden „können“. Darf der Quellenstaat ganz oder teilweise besteuern, muss der Ansässigkeitsstaat nachgelagert die Doppelbesteuerung durch Anwendung des Methodenartikels vermeiden. Es wird insoweit von **Verteilungsnormen** mit **nicht abschließender Rechtsfolge** gesprochen. In Einzelfällen treffen die Verteilungsnormen aber auch eine **abschließende Rechtsfolge**, indem sie anordnen, dass Einkünfte ausschließlich („können nur“) in einem Staat besteuert werden dürfen. In diesen Fällen legt die Verteilungsnorm abschließend die Besteuerung durch nur einen Staat fest. Die Anwendung des Methodenartikels erübrigt sich dann. Diese kleine, aber feine Differenzierung müssen Sie zum Anlass nehmen, die Verteilungsnormen stets sorgfältig zu lesen!

2. „Ansässigkeitsstaat“, „anderer Staat“ und Doppelansässigkeit

Die Verteilungsnormen zielen darauf ab, das Besteuerungsrecht zwischen beiden Staaten aufzuteilen bzw. zu verteilen. Dabei gilt folgendes Prinzip: Im Grundsatz darf zunächst regelmäßig der „Ansässigkeitsstaat“ im Rahmen des Welteinkommensprinzips besteuern.

Dieser hat aufgrund der personenbezogenen Verbindung des Steuerpflichtigen zu seinem Territorium und dem damit einhergehenden Welteinkommensprinzip eine vorrangige Stellung. Ausgehend von dieser vorrangigen Stellung des Ansässigkeitsstaates wird das Besteuerungsrecht punktuell dem „anderen Staat“ zugesprochen. Dies geschieht grundsätzlich in Abhängigkeit von der Intensität der wirtschaftlichen Verbindung von Einkunftsquelle und Territorium des anderen Staates. Besteht keinerlei Verbindung, z. B. bei Drittstaateneinkünften (Art. 20 DE-VHG), so darf der „andere Staat“ überhaupt nicht besteuern und das Besteuerungsrecht liegt allein beim Ansässigkeitsstaat. Besteht eine äußerst intensive Verbindung, z. B. bei einer Betriebsstätte oder Immobilie im Territorium des „anderen Staates“ (Art. 7 Abs. 1 DE-VHG), so darf dieser vollumfänglich, also uneingeschränkt, besteuern. Dazwischen liegen Fälle einer eingeschränkten wirtschaftlichen Verbindung, z. B. bei Erzielung von Dividenden aus dem anderen Staat (Art. 10 DE-VHG), in denen dem „anderen Staat“ ein der Höhe nach begrenztes Besteuerungsrecht zusteht.

Die Anwendung der DBA-Verteilungsartikel setzt folglich eine eindeutige Unterscheidung von „Ansässigkeitsstaat“ und „anderem Staat“ voraus. Eine solche zu erkennen ist nicht immer einfach.

► **Beispiel:**

Die AUT GmbH hat ihren Sitz in Wien (Österreich) und ihre Geschäftsleitung in Berlin (Deutschland). Wo ist die GmbH ansässig? Gehen Sie davon aus, dass die GmbH in Österreich aufgrund ihres Sitzes unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist (§ 1 Abs. 2 öKStG).

► **Lösung:**

Die GmbH ist eine „Person“ i. S. d. Art. 3 Abs. 1 Buchst. d DBA- Österreich und wegen ihres Sitzes in Österreich (§ 1 Abs. 2 öKStG), wegen ihrer Geschäftsleitung (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG, § 10 AO) aber in Deutschland unbeschränkt mit ihrem Welteinkommen steuerpflichtig. Damit ist die GmbH sowohl in Österreich als auch in Deutschland ansässig.

Es liegt auf der Hand, dass dieses Ergebnis – zwei Staaten, die als Ansässigkeitsstaat anzusehen sind – vor dem Hintergrund der Systematik der DBA-Verteilungsnormen – Unterscheidung zwischen Ansässigkeitsstaat und anderem Staat – nicht hinnehmbar ist: Das DBA muss also Regelungen treffen für Fälle sog. Doppelansässigkeiten. Dies geschieht im Rahmen der sog. „tie-breaker“-Regelungen in Art. 4 Abs. 2 und Abs. 3 DE-VHG.

Für Kapitalgesellschaften ist diese Regelung simpel: Im Zweifelsfall gilt (Fiktion!) eine andere als eine natürliche Person, also insbesondere eine juristische Person, nur dort als ansässig, wo sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet (Art. 4 Abs. 3 DE-VHG). Die GmbH aus dem vorigen Beispiel wäre folglich zwar in beiden Staaten ansässig, für Zwecke der Anwendung des DBA gälte sie aber als nur in Deutschland ansässig – Deutschland wäre der Ansässigkeitsstaat, Österreich wäre der „andere Staat“, wenn es um die Anwendung der Verteilungsnormen geht.

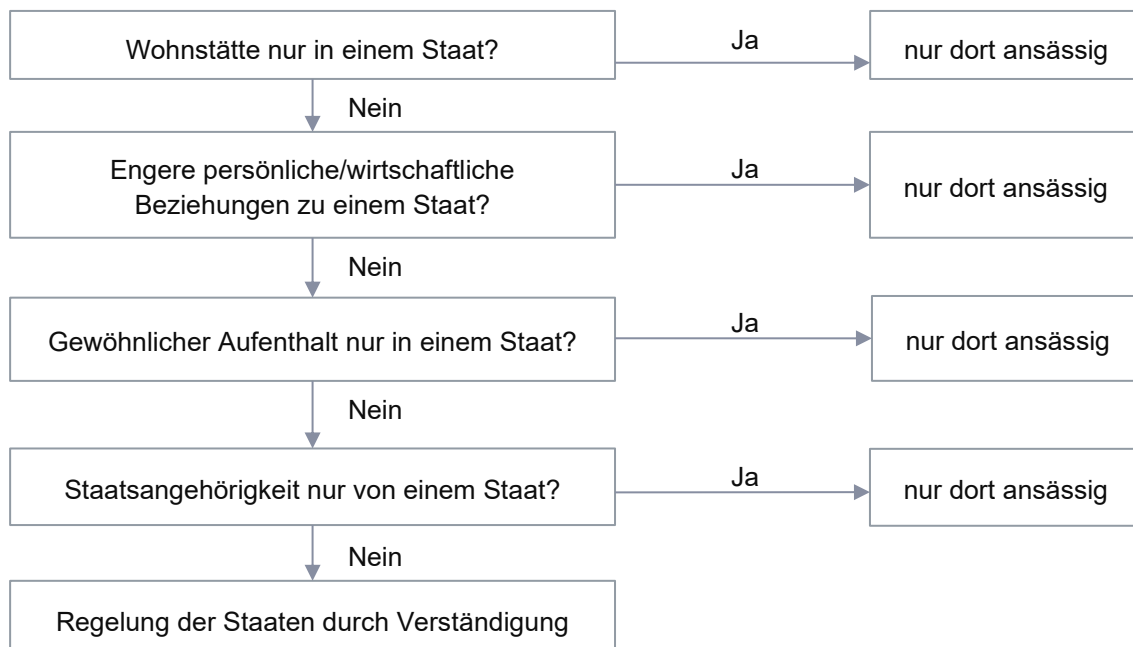
Weniger einfach verhält sich die Auflösung einer Doppelansässigkeit bei natürlichen Personen. Ist die Person in beiden der Staaten nach deren Recht ansässig, muss die Prüfung gem. Art. 4 Abs. 2 DE-VHG fortgesetzt werden. Zunächst ist dabei die ständige Wohnstätte zu überprüfen. Unterhält die Person eine ständige Wohnstätte (einen in den allgemeinen Lebensrhythmus einbezogenen „qualifizierten“ Wohnsitz) in beiden Staaten, kommt es auf den Mittelpunkt der Lebensinteressen an. Festgestellt wird dieser anhand der engeren persönlichen (insbes. familiären) und wirtschaftlichen Beziehungen. Ist der Mittelpunkt der Lebensinteressen nicht festzustellen oder liegt in keinem der beiden Staaten eine Wohnstätte vor, so richtet sich die Ansässigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt. Ist der gewöhnliche Aufenthalt in beiden oder in keinem der Staaten, so ist die Staatsangehörigkeit entscheidend. Hat die Person die Staatsangehörigkeit beider Staaten oder keines der beteiligten Staaten so muss die Ansässigkeit im Verständigungsverfahren (Art. 24 DE-VHG) zwischen beiden Staaten festgelegt werden.



HINWEIS

Vielleicht haben Sie es bemerkt: Art. 4 Abs. 2 DE-VHG geht von der Möglichkeit aus, dass eine Person in beiden Staaten ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der Begriff ist somit nicht mit dem des § 9 AO deckungsgleich, denn einen gewöhnlichen Aufenthalt i. S. v §. 9 AO kann eine Person stets nur in einem Staat haben.

Die nachfolgende Grafik gibt Ihnen einen Überblick über die Prüfungssystematik, wenn eine natürliche Person in beiden Staaten nach Art. 4 Abs. 2 DE-VHG ansässig ist:





VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

DBA-Verteilungsartikel – v10859

3. Darstellung der einzelnen Einkunftsarten

3.1 Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen (Art. 6 DE-VHG)

Art. 6 DE-VHG (und auch OECD-MA) regelt die Besteuerung für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, die eine in einem Staat ansässige Person erzielt: Diese Einkünfte dürfen in dem anderen Staat besteuert werden, in dem das Vermögen liegt (Belegenheitsprinzip). Die Vorschrift erfasst also – ebenso wie die meisten im Folgenden besprochenen Verteilungsnormen – nur den bilateralen Fall, in dem die Person in einem der beiden DBA-Vertragsstaaten ansässig ist und das unbewegliche Vermögen im anderen der beiden DBA-Vertragsstaaten liegt (eine Auffangvorschrift für nicht diesen bilateralen Fall betreffende Einkünfte enthält Art. 20 DE-VHG). Eine Definition des unbeweglichen Vermögens enthält Art. 6 Abs. 2 DE-VHG: Zunächst wird dabei auf das nationale Recht des Belegenheitsstaates verwiesen (Satz 1). Anschließend wird ein Mindestumfang definiert, so gehört ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb stets zum unbeweglichen Vermögen (Satz 2), es werden aber auch Ausnahmen formuliert (Satz 3).

► **Beispiel:**

Der Steuerpflichtige Klaus Störtebecker (ansässig in den Niederlanden, Annahme: DBA entspricht der DE-VHG) besitzt ein Schiff, welches im Hamburger Hafen liegt und in ein deutsches Schiffsregister eingetragen ist. Er fragt sich, ob er von Art. 6 DE-VHG erfasst wird.

► **Lösung:**

Deutschland ist der potenzielle Belegenheitsstaat, weshalb gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 auf das deutsche Recht abzustellen ist. Zum unbeweglichem Vermögen nach deutschem Einkommensteuerrecht (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) gehören Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile, Schiffe, die in ein Schiffsregister eingetragen sind, und Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht). Demnach scheint auch das Schiff von Störtebecker erfasst zu sein. Allerdings gilt der Verweis auf das nationale Recht nur in den Grenzen der weiteren Vorgaben des Art. 6 Abs. 2 DE-VHG, nach dessen Satz 3 jedoch Schiffe und Luftfahrzeuge nicht als unbewegliches Vermögen gelten.

Aus dem Gesamtkontext des DBA ergibt sich, dass Art. 6 DE-VHG nur für die Einkünfte aus der Nutzung unbeweglichen Vermögens gilt, nicht jedoch für die Veräußerung (Art. 13 Abs. 1 DE-VHG) oder die Vermögensbesteuerung (Art. 21 DE-VHG). Der Begriff Einkünfte umfasst positive und negative Einkünfte, weshalb auch das Besteuerungsrecht für negative Einkünfte dem Belegenheitsstaat zugewiesen werden kann. Art. 6 Abs. 4 DE-VHG regelt abschließend, dass Art. 6 auch bei im Rahmen eines Unternehmens erzielten Einkünften aus unbeweglichem Vermögen zur Anwendung kommt, folglich als Spezialnorm vorgeht.

3.2 Unternehmensgewinne (Art. 7 DE-VHG)

Nach Art. 7 Abs. 1 DE-VHG (und auch OECD-MA) können Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats nur in diesem Staat (also im Ansässigkeitsstaat) besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen Staat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Die Anwendung dieser Vorschrift über Unternehmensgewinne erfordert in mehrfacher Hinsicht den Rückgriff auf die Begriffsbestimmungen des Abkommens.

Zunächst gibt Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 DE-VHG vor, dass der Begriff „Unternehmen“ sich auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit bezieht. Nach überwiegender Auffassung ist hinsichtlich des Begriffs der Geschäftstätigkeit auf die Grundzüge des § 15 EStG abzustellen: Demzufolge wird eine Geschäftstätigkeit selbständig, nachhaltig, mit Gewinnerzielungsabsicht und unter Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ausgeübt, wobei keine bloße Vermögensverwaltung vorliegt. Eine Geschäftstätigkeit umfasst aber neben gewerblichen Tätigkeiten auch solche i. S. v. § 18 EStG.

► **Beispiel:**

Der Schwede Lars Larsson ist an einer rein gewerblich geprägten Personengesellschaft im Inland (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG) beteiligt. Erzielt er abkommensrechtlich Unternehmensgewinne?

► **Lösung:**

Nein! Der BFH (Urteil vom 25.5.2011, BStBl. 2014 II, 760) hat entschieden, das Vorliegen von Unternehmensgewinnen erfordert ein „Ausüben“ einer unternehmerischen Tätigkeit, welche bei einer gewerblichen Prägung nicht vorliegt. Die Begriffe Unternehmen und Gewerbebetrieb ähneln sich daher zwar, sind aber nicht identisch. Insbesondere kann nicht auf innerstaatliche Fiktionen zurückgegriffen werden! Infolge der gebotenen abkommensautonomen Auslegung sind auch die gewerbliche Infizierung und die Betriebsaufspaltung nicht von Art. 7 DE-VHG erfasst.

Um die Besteuerungsrechte zwischen den beiden Staaten zu verteilen, ist es sodann erforderlich, festzulegen, wann ein „Unternehmen eines Vertragsstaats“ vorliegt. Dies wird in Art. 3 Abs. 1 Nr. 6 DE-VHG als ein von einer in diesem Vertragsstaat ansässigen Person betriebenes Unternehmen definiert.

► **Beispiel:**

Der in Schweden ansässige Stefan Ettberg und der in Deutschland ansässige Boris Bäcker sind gemeinsam an einer unternehmerisch tätigen Personengesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung in Großbritannien beteiligt? Welchem Staat ist das Unternehmen der Personengesellschaft zuzuordnen.

► **Lösung:**

Wie wir gelernt haben, ist die Personengesellschaft zwar „Person“, aber mangels Steuerpflicht regelmäßig nicht „ansässige Person“. Daher kann das Unternehmen nicht der Personengesellschaft zugeordnet werden. Es ist also auf die Gesellschafter abzustellen. Da diese sowohl in Schweden als auch in Deutschland ansässig sind, liegen (anteilig) sowohl ein Unternehmen des Vertragsstaats Schweden (aus Sicht des Gesellschafters Ettberg) als auch ein Unternehmen des Vertragsstaats Deutschland (aus Sicht des Gesellschafters Bäcker) vor.

Wird das Unternehmen auf diese Weise einem Vertragsstaat zugeordnet, so darf grundsätzlich nur in diesem Staat der Unternehmensgewinn besteuert werden. Eine Ausnahme davon, also ein Besteuerungsrecht des anderen Staates, ergibt sich nur, wenn sich dort eine „Betriebsstätte“ befindet. Der Begriff „Betriebsstätte“ wird umfassend in Art. 5 DE-VHG definiert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Definition einmal komplett zu lesen. Weitgehend entspricht die Definition (Art. 5 Abs. 1 DE-VHG) den Vorgaben des Art. 12 Satz 1 AO. In Prüfungsfällen sollten Sie stets die Beispiele in Art. 5 Abs. 2 DE-VHG heranziehen, die i. d. R. die Voraussetzungen der Betriebsstättendefinition erfüllen. Zu beachten ist die unterschiedliche Frist für eine Bau- und Montagebetriebsstätte gemäß Art. 5 Abs. 3 DE-VHG (12 Monate) und § 12 Satz 2 Nr. 8 AO (6 Monate). Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Ausnahmen des Art. 5 Abs. 4 DE-VHG für unterstützende und vorbereitende Tätigkeiten. Eine vorbereitende oder unterstützende (Hilfs-)Tätigkeit liegt insbesondere vor, wenn eine Einrichtung nur für das Unternehmen wirbt, Informationen sammelt oder Forschung betreibt. In diesen Fällen wird – trotz Erfüllung der Betriebsstättenvoraussetzungen – das Nicht-Vorliegen einer (abkommensrechtlichen) Betriebsstätte fingiert.



Liegt eine Betriebsstätte im anderen Staat vor, so darf dieser die Einkünfte besteuern, die der Betriebsstätte zuzurechnen sind (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 DE-VHG). Wenngleich Art. 7 DE-VHG von „Gewinnen“ eines Unternehmens spricht, werden hiervon ebenfalls Verluste erfasst und das Besteuerungsrecht an diesen Verlusten verteilt. Erwähnenswert ist die das Update zum OECD-MA 2010 erfolgte Umsetzung des sog. „Authorized OECD Approach“, den auch Art. 7 DE-VHG enthält. Danach wird jede Betriebsstätte bei der Bestimmung „ihrer“ Einkünfte wie ein eigenständiges Unternehmen behandelt (Art. 7 Abs. 2 DE-VHG). Demnach sind einerseits fiktive Geschäftsbeziehungen zwischen den verschiedenen Betriebsstätten denkbar (also z. B. die fiktive Überlassung eines Patents, welches in einer Betriebsstätte entwickelt und in einer anderen genutzt wird), andererseits kann aber auch dann einer Betriebsstätte ein positives Ergebnis zugerechnet werden, wenn das Gesamtunternehmen, zu dem die Betriebsstätte gehört, ein negatives Ergebnis erzielt.

Gemäß Art. 7 Abs. 4 DE-VHG gilt der Spezialitätsgrundsatz! Werden also im Rahmen eines Unternehmens Einkünfte erzielt, die auch in anderen Verteilungsnormen behandelt werden (z. B. Zinseinkünfte einer Bank), so geht stets die spezielle Verteilungsnorm vor.

► **Beispiel:**

Der selbständige Rechtsanwalt Günther Gerechtigkeit hat die vorigen Ausführungen aufmerksam gelesen. Er fragt sich, ob er ebenfalls Unternehmensgewinne i. S. d. Abkommensrechts erzielt.

► **Lösung:**

Hier ist zu unterscheiden: Nach der DE-VHG und allen in jüngerer Vergangenheit abgeschlossenen deutschen DBA erzielt Günther Unternehmensgewinne. Er übt nämlich eine Geschäftstätigkeit aus, wie Art. 3 Abs. 1 Nr. 5 DE-VHG für freiberufliche und alle sonstigen selbständigen Tätigkeiten klarstellt. In älteren deutschen DBA finden Sie dagegen oftmals einen Art. 14 (in Anlehnung an Art. 14 OECD-MA a. F.), der die Überschrift „Einkünfte aus selbständiger Arbeit“ trägt. In diesen Fällen gibt es eine Spezialnorm, die wegen Art. 7 Abs. 4 DE-VHG vorgeht. Selbständige Arbeit wird in Art. 14 Abs. 2 OECD-MA a. F. definiert und entspricht in weiten Teilen der Definition in § 18 EStG. Art. 14 OECD-MA a. F. basiert auf demselben Prinzip wie Art. 7, allerdings wird für ein Besteuerungsrecht des anderen Staats keine „Betriebsstätte“, sondern eine „feste Einrichtung“ vorausgesetzt. Da allerdings eine „feste Einrichtung“ mangels eigenständiger Definition ebenfalls nach den Grundsätzen des Art. 5 OECD-MA bestimmt wird (per Analogie), ergeben sich insoweit kaum Unterschiede.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünfte aus selbstständigen Tätigkeiten in DBA – v10860

3.3 Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und Luftfahrt (Art. 8 DE-VHG)

Art. 8 DE-VHG enthält eine Spezialregelung für Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen oder Luftfahrzeugen (zum Begriff auch Art. 8 Abs. 3 und Abs. 5 DE-VHG), die Art. 7 DE-VHG vorgeht. Sowohl im Bereich der Seeschifffahrt und der Luftfahrt im internationalen Verkehr (Art. 8 Abs. 1 DE-VHG) als auch im Bereich der Binnenschifffahrt (Art. 8 Abs. 2 DE-VHG) dürfen demnach die Gewinne nur dort besteuert werden, wo sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Auf eine Betriebsstätte kommt es folglich nicht an. Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung an Bord eines Schiffes, so ist auf den Heimathafen des Schiffes abzustellen (Art. 8 Abs. 4 DE-VHG). Der Begriff „internationaler Verkehr“ wird in Art. 3 Abs. 1 Nr. 7 DE-VHG definiert.

3.4 Einkünftekorrektur (Art. 9 DE-VHG)

Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen grundsätzlich nur in diesem Staat besteuert werden. Dies entfaltet für den Steuerpflichtigen eine Schutzwirkung, mit diesen Gewinnen nicht in anderen Staaten besteuert zu werden (Ausnahme: wenn dort eine Betriebsstätte vorliegt). Diese Schutzwirkung soll gleichwohl nicht dahingehend missbraucht werden können, die in einem Staat – vorzugsweise einem niedrig besteuerten – anfallenden Unternehmensgewinne künstlich zu erhöhen, z. B. durch nicht fremdübliche Bepreisung von Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen. Vor dem Hintergrund dieses Problems ergänzt Art. 9 DE-VHG die Regelungen zu Unternehmensgewinnen: Nach Art. 9 Abs. 1 DE-VHG darf ein Staat, wenn zwei miteinander verbundene Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen fremdunübliche Bedingungen vereinbaren, die zu einer Minderung der in diesem Staat erzielten Unternehmensgewinne führen, die geminderten Gewinn hinzurechnen und besteuern. Die Norm betrifft vor allem Einkünftekorrekturen in Form der verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) oder nach § 1 AStG (siehe dazu auch Lehrbrief IStR 03).

Ähnlich wie bei der vGA (dort neben formeller Korrespondenz in § 32a KStG auch materielle Korrespondenz in § 8b Abs. 1 Satz 2 ff. KStG) sieht das DBA eine Korrespondenz vor: So soll, wenn ein Staat eine Erhöhung der Unternehmensgewinn nach Art. 9 Abs. 1 DE-VHG vornimmt, der andere Staat nach Art. 9 Abs. 2 DE-VHG eine Gegenkorrektur der Gewinne des anderen Unternehmens vornehmen, um eine anderenfalls drohende wirtschaftliche Doppelbesteuerung zu vermeiden. Viele deutsche DBA enthalten noch keine entsprechende Korrespondenz.

3.5 Dividenden (Art. 10 DE-VHG)

Das Besteuerungsrecht an zwischen den Vertragsstaaten gezahlten Dividenden wird in Art. 10 DE-VHG geregelt. Die Regelung ist zweistufig aufgebaut: Zunächst spricht Art. 10 Abs. 1 DE-VHG dem Ansässigkeitsstaat der die Dividende empfangenden Person das Besteuerungsrecht zu, anschließend erhält der Staat, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist (Quellenstaat), ein der Höhe nach begrenztes Quellenbesteuerungsrecht. Letzteres richtet sich der Höhe nach danach, ob die Voraussetzungen des Schachtelprivilegs erfüllt sind oder nicht.

Was eine Dividende ist, wird in Art. 10 Abs. 3 DE-VHG definiert. Dividenden sind insbesondere Einkünfte aus Gesellschaftsanteilen, Genussrechten, Genussscheinen oder Gründeranteilen. Durch ein Abstellen auf Gesellschaftsanteile werden sämtliche Einkünfte aus Anteilen an einer AG oder GmbH erfasst (also insbesondere offene und verdeckte Gewinnausschüttungen von AG oder GmbH). Dies ist jedoch nicht selbstverständlich. Denn im Einklang mit Art. 10 Abs. 3 OECD-MA stellen viele deutsche DBA anstatt auf „Gesellschaftsanteile“ auf „Aktien“ ab, weshalb nur Einkünfte aus AG-Anteilen erfasst werden. Für die Erfassung von Einkünften aus GmbH-Anteilen ist in diesen Fällen auf einen – sowohl in der DE-VHG als auch im OECD-MA enthaltenen – Auffangtatbestand abzustellen, dem zufolge den Dividenden auch sonstige Einkünfte (OECD-MA: aus Gesellschaftsanteilen), die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Gesellschaftsanteilen (OECD-MA: aus Aktien) gleichgestellt sind.

► **Beispiel:**

Der in Deutschland ansässige Steuerpflichtige Jürgen Drehs besitzt eine Finca auf Mallorca, die er über eine spanische Kapitalgesellschaft (S. L., entspricht einer deutschen GmbH) hält. Da er die Finca unentgeltlich nutzt, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Handelt es sich hierbei um eine „Dividende“ i. S. d. DBA-Spanien?



► **Lösung:**

Es kommt darauf an! Art. 10 Abs. 3 DBA-Spanien 2011 stellt ebenso wie das OECD-MA (und anders als die DE-VHG, die auf „Gesellschaftsanteile“ abstellt) auf „Einkünfte aus Aktien“ ab, worunter die Ausschüttungen von der S. L. nicht fallen, weil es sich um eine einer GmbH vergleichbare Gesellschaftsform handelt. Ob die Einkünfte „Dividenden“ sind, hängt folglich davon ab, ob Spanien als Ansässigkeitsstaat der Gesellschaft die Einkünfte (vorliegend als die verdeckte (!) Gewinnausschüttung) steuerlich den Einkünften aus Aktien gleichstellt.

Wenngleich dies bei offenen Gewinnausschüttungen in den meisten Staaten der Fall ist, muss bei verdeckten Gewinnausschüttungen umso genauer hingeschaut werden: Vorliegend ist es jedoch so, dass Spanien – ebenso wie Deutschland (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG) – verdeckte Gewinnausschüttungen kennt und diese auch den Einkünften aus Aktien gleichstellt. Es liegen folglich Dividenden i. S. d. DBA vor.



HINWEIS

Sie merken sich bitte: Bei verdeckten Gewinnausschüttungen kommt es hinsichtlich der Frage, ob abkommensrechtlich Dividenden vorliegen, oftmals darauf an, ob der Staat, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, verdeckte Gewinnausschüttungen wie Einkünfte aus Aktien behandelt. Entscheidend ist hierbei allein die abstrakte Behandlung, nicht die tatsächliche Behandlung im konkreten Einzelfall. Eine verdeckte Gewinnausschüttung einer deutschen Kapitalgesellschaft stellt somit selbst dann eine „Dividende“ i. S. d. Abkommens dar, wenn diese im Einzelfall gar nicht aufgedeckt wurde.

Art. 10 Abs. 4 DE-VHG enthält den sog. „Betriebsstättenvorbehalt“, eine Sonderregelung, die uns auch in weiteren Vorschriften noch begegnen wird.

Um den Sinn dieser Regelung zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, dass das Abkommen dem anderen Staat – also dem Nicht- Ansässigkeitsstaat – ein Besteuerungsrecht in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Verbindung zu dessen Territorium zuspricht. Die dabei bestehenden Unterschiede können in Verbindung mit dem Spezialitätsgrundsatz des DBA zu Verwerfungen führen.

► **Beispiel:**

Der in Deutschland ansässige Paul Panther ist an einer spanischen S. C. (entspricht einer deutschen KG) beteiligt, die produzierend tätig ist. Paul Panther hält ebenfalls Anteile an zwei spanischen S. L. (entspricht einer deutschen GmbH), die als persönlich haftende Gesellschafterin der S. C. bzw. als Vertriebsgesellschaft tätig sind. Wie werden die Gewinnausschüttungen der beiden S. L. abkommensrechtlich behandelt?

► **Lösung:**

Die Produktionsstätte der Personengesellschaft stellt – infolge der aus deutscher Sicht bestehenden Transparenz – eine Betriebsstätte dar (Art. 5 Abs. 2 Buchst. d DBA-Spanien), die Paul Panther mangels Ansässigkeit der Personengesellschaft anteilig als seine eigene zugerechnet wird. Die Gewinne aus der Produktion sind der Betriebsstätte zuzurechnen und können daher in Spanien besteuert werden (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 DBA-Spanien). Fraglich ist, was mit den Gewinnausschüttungen geschieht: Diese stellen zwar, da sie Teil einer unternehmerischen Tätigkeit sind, im Grundsatz Unternehmensgewinne dar (Art. 7 DBA-Spanien), welche aber dem Spezialitätsgrundsatz (Art. 7 Abs. 6 DBA-Spanien) unterfallen und daher Art. 10 DBA-Spanien unterliegen. Dies führte zu der grundsätzlichen Verwerfung, dass hier aktiv genutzte Wirtschaftsgüter, die im Regelfall ein vollumfängliches Besteuerungsrecht des Quellenstaates rechtfertigen, einer Norm für passiv verwaltete Wirtschaftsgüter unterliegen, die nur ein begrenztes Quellenbesteuerungsrecht vorsieht. Art. 10 Abs. 4 DBA-Spanien sieht daher einen Rückverweis auf Art. 7 DBA-Spanien vor: Wenn die Beteiligung tatsächlich zu einer Betriebsstätte des Steuer-

pflichtigen im anderen Staat gehört, findet Art. 7 DBA-Spanien – nun also doch und ausnahmsweise entgegen dem Spezialitätsgrundsatz – vorrangig Anwendung. Dies ist erfüllt, weil die Beteiligungen im vorliegenden Fall aktiv im Rahmen der Unternehmenstätigkeit genutzt werden (funktionaler Zusammenhang). Einen solchen funktionalen Zusammenhang wird man im vorliegenden Fall bejahen können.

Die für den Betriebsstättenvorbehalt erforderliche „tatsächliche Zugehörigkeit“ war in der Vergangenheit mit Rechtsunsicherheit behaftet. Für nach dem 31.12.2014 beginnende Wirtschaftsjahre findet jedoch die Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV) Anwendung, die in § 7 Grundsätze für die Zuordnung von Beteiligungen enthält. Erläutert werden diese Grundsätze ausführlich in den Betriebsstättenverwaltungsgrundsätzen (BMF v. 22.12.2016, BStBl. 2017 I S. 182, Beck-Steuererlasse 800 § 12/1, Tz. 2.7). Auf Basis solch detaillierter Ausführungen kann ein Prüfer leicht eine rechtsichere Prüfungsaufgabe formulieren.

3.6 Zinsen und Lizenzgebühren (Art. 11 und Art. 12 DE-VHG)

Die Verteilungsnormen für Zinsen und Lizenzgebühren ähneln derjenigen für Dividenden insoweit, als der Grundsatz der Besteuerung im Ansässigkeitsstaat (Abs. 1) gilt. Die Parallelen erklären sich dadurch, dass es sich bei den Art. 10 bis 12 um die Besteuerung von aus passiven Vermögenswerten erzielten Einkünften handelt. Anders als bei Dividenden und teilweise abweichend vom OECD-MA (dort Art. 11 Abs. 2 für Zinsen) sieht die DE-VHG aber für Zinsen und Lizenzgebühren kein Quellenbesteuerungsrecht vor, d. h. es darf nur der Ansässigkeitsstaat besteuern. In einer Prüfungsaufgabe, d. h. in einem konkreten Ihnen zur Verfügung gestellten DBA, müssen Sie dies natürlich prüfen und oftmals enthalten deutsche DBA sehr wohl ein begrenztes Quellenbesteuerungsrecht auch für Zinsen bzw. Lizenzgebühren. Zinsen sind abkommensrechtlich „Einkünfte aus Forderungen jeder Art“, wobei aber Zuschläge für verspätete Zahlungen (Verzugszinsen) nicht erfasst werden (Art. 11 Abs. 2 DE-VHG). Lizenzgebühren liegen nach Art. 12 Abs. 2 DE-VHG vor, wenn Zahlungen jeder Art geleistet werden als Gegenleistung für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken (insbesondere Patente, Warenzeichen, etc.).

Sowohl der Zins- als auch der Lizenzartikel enthalten in Abs. 3 einen Betriebsstättenvorbehalt, den Sie aus Art. 10 Abs. 4 DE-VHG bereits kennen. Wenn die Forderung oder der Vermögenswert, aus dem Lizenzgebühren generiert werden, tatsächlich zu einer Betriebsstätte im Quellenstaat gehört, so darf der Quellenstaat nach den Grundsätzen des Art. 7 DE-VHG – und abweichend von Art. 11 und 12 DE-VHG – vollumfänglich besteuern.

Die BsGaV enthält in den §§ 5 bis 8 Regelungen für die Zuordnung, insbesondere in § 6 Grundsätze für die Zuordnung von immateriellen Vermögenswerten, die es im Rahmen der Zuordnung von Wirtschaftsgütern im Anwendungsbereich von DBA zu beachten gilt.

Eine weitere Besonderheit teilen Art. 11 und Art. 12 DE-VHG in Abs. 4: Dort geht es um der Höhe nach unangemessene Zinsen und Lizenzgebühren. Der fremdunübliche Teil unterliegt nicht den Einschränkungen der Art. 11 bzw. Art. 12 DE-VHG, sondern kann unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen des Abkommens besteuert werden. Maßgeblich wird insoweit oftmals eine Behandlung als verdeckte Gewinnausschüttung sein (Art. 10 DE-VHG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünfte aus Wirtschaftsgütern in DBA – v10862



3.7 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen (Art. 13 DE-VHG)

Art. 13 DE-VHG betrifft die Veräußerung von Vermögen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen Einklang zwischen der Verteilung der Besteuerungsrechte an den laufenden Einkünften und an den Veräußerungsgewinnen vorzunehmen. Daraus ergibt sich, dass

- die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen i. S. d. Art. 6 DE-VHG ebenso wie die laufenden Einkünfte im Belegenheitsstaat besteuert werden darf (Abs. 1),
- die Veräußerung von beweglichem Betriebsstättenvermögen (also einer Betriebsstätte zugeordnetem Vermögen) i. S. v. Art. 7 DE-VHG ebenso wie die laufenden Gewinne im Betriebsstättenstaat besteuert werden darf (Abs. 2),
- die Veräußerung von Schiffen oder Luftfahrzeugen i. S. v. Art. 8 DE-VHG ebenso wie die laufenden Gewinne in dem Vertragsstaat, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet, besteuert werden darf (Abs. 3).

Ausgehend von diesen „systematischen“ Regelungen, befindet sich in Art. 13 Abs. 5 DE-VHG eine Auffangvorschrift, wonach alle Vermögenswerte, die in den Abs. 1 bis 4 nicht erwähnt wurden, nur im Ansässigkeitsstaat des Veräußernden besteuert werden dürfen. Diese Vorschrift betrifft vor allem Beteiligungen, bei denen es sich schwierig gestalten würde, den Veräußerungsgewinn, ebenso wie die laufenden Einkünfte, anteilig zwischen den Staaten zu verteilen. Im Regelfall wird es als angemessen angesehen, das Besteuerungsrecht aus der Beteiligungsveräußerung dem Ansässigkeitsstaat des Veräußerers zuzusprechen. Dies gilt nach Art. 13 Abs. 4 DE-VHG jedoch nicht für solche Gesellschaftsanteile, deren Wert zu mehr als 50 % unmittelbar oder mittelbar auf unbeweglichem Vermögen beruht. Dann kann der Belegenheitsstaat des unbeweglichen Vermögens besteuern. Der Anteil errechnet sich, indem der Wert aller unter Art. 6 Abs. 2 bzw. Art. 13 Abs. 1 DE-VHG fallenden Vermögenswerte (unbewegliches Vermögen) sowie Gesellschaftsanteile, soweit deren Wert aus unbeweglichem Vermögen besteht, ins Verhältnis zum Gesamtvermögen (ohne Verbindlichkeiten) gesetzt wird. Nicht abschließend geklärt ist, ob insoweit gemeine Werte oder Buchwerte anzusetzen sind. In Anlehnung an § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppelbuchst. cc EStG dürfte aus deutscher Sicht auf Buchwerte gemäß Steuerbilanz zurückzugreifen sein. Teilweise finden sich relevante Hinweise im betreffenden DBA (siehe Tz. 4 des Protokolls zum DBA-Österreich, wonach auf die Aktivwerte laut Handelsbilanz abzustellen ist).



HINWEIS

In einer Prüfung kann es entscheidend sein, solche Feinheiten zu kennen. Ein Prüfer kann Ihnen z. B. einen Sachverhalt schildern, bei dem eine Gesellschaft ihr Vermögen umschichtet, es aber um die Besteuerung des Anteilseigners geht. So kann es durch Umschichtungen auf Gesellschaftsebene zu einem Wechsel des Besteuerungsrechtes an der Beteiligungsveräußerung auf Gesellschafterebene kommen, die eine Wegzugsbesteuerung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AStG auslöst (dazu Modul IStR 03).

Auch die Wegzugsbesteuerung ist in Art. 13 Abs. 6 DE-VHG angesprochen. War eine natürliche Person mindestens fünf Jahre in einem Staat ansässig und verzieht sie in den anderen Staat (und ist dort ansässig geworden), so darf der ehemalige Ansässigkeitsstaat die Person so behandeln, als habe sie im Wegzugszeitpunkt ihre Anteile an Gesellschaften veräußert. Die Anwendung des § 6 AStG wird folglich abkommensrechtlich legitimiert, woraus Sie aber bitte nicht schließen, dass § 6 AStG nicht angewendet wird, wenn das DBA keine entsprechende Regelung enthält. Nur einige deutsche DBA enthalten nämlich eine solche Vorschrift. Für die Praxis ist insbesondere Satz 2 wichtig, der eine Wertverknüpfung im Zuzugsstaat anordnet und damit eine durch die Wegzugsbesteuerung ausgelöste Doppelbesteuerung verhindert.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünfte aus Veräußerungen in DBA – v10863

3.8 Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (Art. 14 DE-VHG)

Art. 14 DE-VHG betrifft unselbständige Arbeit, was im Einklang mit dem nationalen Verständnis jede weisungsgebundene Tätigkeit i. S. v. § 19 EStG meint. Der Grundsatz bei Einkünften aus unselbständiger Arbeit ist die Besteuerung im Ansässigkeitsstaat, die allerdings insoweit durchbrochen wird, als bei Ausübung der Arbeit im anderen Staat die „dafür“ bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden können (Art. 14 Abs. 1 DE-VHG).

► Beispiel:

Michl Mittermeier wohnt in München und ist als Auslandskorrespondent für eine österreichische Tageszeitung in Wien tätig. Zwei Tage pro Woche arbeitet er von daheim, zwei Tage verbringt er im Wiener Büro und einen Tag ist er in der Regel in anderen Staaten auf der Jagd nach Schlagzeilen. Wem steht das Besteuerungsrecht zu?

► Lösung:

Michl Mittermeier ist unselbständig tätig, weil er Angestellter ist. Das Besteuerungsrecht steht grundsätzlich dem Ansässigkeitsstaat zu, wobei die „für“ die in Österreich ausgeübte Tätigkeit erzielten Einkünfte auch dort besteuert werden können. Dies betrifft allerdings nur die Tage der tatsächlichen Anwesenheit im „anderen Staat“ Österreich, also nur zwei von fünf Tagen (vgl. auch BFH, Urteil v. 25.11.2014, BStBl. 2015 II, 448). Das Besteuerungsrecht für die in Drittstaaten ausgeübte Tätigkeit steht nicht mehr Österreich zu. Insoweit darf Deutschland besteuern, muss aber prüfen, ob mit dem Drittstaat ein gesondert zu prüfendes DBA besteht.

Art. 14 Abs. 1 DE-VHG erfordert also regelmäßig eine Aufteilung des Arbeitslohns nach dem Tätigkeitsort. Diese Aufteilung erfolgt grundsätzlich zweistufig: Zunächst erfolgt eine direkte Zuordnung des Arbeitslohns, wenn dieser aufgrund einer konkreten inländischen oder ausländischen Tätigkeit gewährt wird (z. B. Risikozuschlag bei Reise in ein Kriegsgebiet). Der verbleibende, weil nicht direkt zuordenbare, Arbeitslohn ist auf Basis der tatsächlichen Arbeitstage aufzuteilen.

Sie finden ausführliche Ausführungen dazu im BMF-Schreiben v. 12.12.2023, BStBl. 2023 I, S. 2179, Tz. 5 ab Rn. 227 ff.¹ Bitte machen Sie sich grob mit dem Inhalt dieses BMF-Schreibens vertraut und „speichern“ Sie dessen Existenz ab. Solch umfangreiche Ausführungen können Prüfer geradezu einladen, eine rechtsichere Prüfungsaufgabe zu formulieren.

Eine Vereinfachungsregelung enthält Art. 14 Abs. 2 DE-VHG – die sog. 183-Tage-Regel. Diese Regelung gilt „ungeachtet des Absatzes 1“ (also ungeachtet des Tätigkeitsortsprinzips) und sieht unter drei – kumulativ zu erfüllenden – Voraussetzungen ein ausschließliches Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates vor:

- Wenn der Empfänger sich nicht länger als 183 Tage im Tätigkeitsstaat aufhält (**Achtung:** Der Bezugszeitraum für die 183 Tage variiert in deutschen DBA. In der DE-VHG geht es um einen Zeitraum von zwölf Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt oder endet, in einigen DBA wird stattdessen auf das Steuer- oder Kalenderjahr abgestellt),
- Die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im anderen Staat (also Tätigkeitsstaat) ansässig ist,

¹ BMF-Schreiben, bei denen ausschließlich die Fundstelle im BStBl. angegeben ist, sind in den Beck'schen Steuererlassen nicht enthalten.



- Die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte des Arbeitgebers im anderen Staat getragen werden.

Auch bezüglich der 183-Tage-Regel nehmen Sie bitte die umfangreichen Ausführungen des BMF-Schreibens zur Kenntnis (BMF-Schreiben v. 12.12.2023, BStBl. 2023 I, S. 2179, Tz. 4 ab Rn. 101 ff.). Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit der 183-Tage-Regel kann die Frage sein, wer "Arbeitgeber" des Steuerpflichtigen ist. In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass hier keine zivilrechtliche, sondern eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zur Anwendung kommt. Im Kern wird demnach ein Unternehmen auch ohne Arbeitsvertrag als "wirtschaftlicher Arbeitgeber" angesehen, wenn der Arbeitnehmer in dieses Unternehmen organisatorisch eingebunden ist (z.B. das Unternehmen über Art und Umfang der Tätigkeiten entscheidet, aber auch wenn eine Person als Geschäftsführer tätig wird) und das Unternehmen den Arbeitslohn trägt oder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz hätte tragen müssen. Auch hierzu finden Sie umfangreiche Hinweise im BMF-Schreiben v. 12.12.2023, BStBl. 2023 I, S. 2179, Tz. 4.3.3.3, Rn. 151 ff.

Einkünfte aus einer an Bord eines Schiffs oder eines Luftfahrzeugs ausgeübten unselbständigen Tätigkeit können im Einklang mit Art. 8 DE-VHG in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des betreibenden Unternehmens befindet. Insofern wird vom Tätigkeitsortprinzip abgewichen.

Eine Sonderregelung die Abziehbarkeit von Beiträgen zur Altersvorsorge betreffend enthält Art. 14 Abs. 4 bis Abs. 6 DE-VHG. Dadurch soll für grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer sichergestellt werden, dass deren Beiträge zu den Einrichtungen in ihrem Ansässigkeitsstaat im Tätigkeitsstaat abziehbar sind. Eine ähnliche Regelung enthält z. B. Art. 15 Abs. 7 DBA-Österreich.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünfte aus unselbstständigen Tätigkeiten in DBA – v10861

3.9 Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen (Art. 15 DE-VHG)

Gemäß Art. 15 DE-VHG können Vergütungen, die eine in einem Staat ansässige Person für eine Tätigkeit als Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Staat ansässig ist, im anderen Staat besteuert werden. Es kommt hierbei nicht darauf, wo die Tätigkeit ausgeübt wird, sondern es ist allein die Ansässigkeit der Gesellschaft maßgeblich.

Die Begriffe Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat sind im Abkommensrecht nicht definiert. Nach deutschem Recht versteht man unter einem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat eine Person, die die Geschäftsführung einer Gesellschaft überwacht. Der Begriff der Überwachung ist weit auszulegen. Die Art der Vergütung (Pauschalzahlung, Vergütung pro Sitzung, erfolgsabhängige Vergütung) ist unerheblich.



HINWEIS

In einigen deutschen DBA (z. B. mit Österreich oder Polen) wird die Art. 15 DE-VHG entsprechende Regelung auch auf Geschäftsführer angewendet. Fehlt eine entsprechende Sonderregelung, fällt die Tätigkeit als Geschäftsführer unter die Verteilungsnorm für unselbständige Arbeit, wobei auch in diesen Fällen teilweise Sonderregelungen in DBA vereinbart sind (so z. B. Art. 15 Abs. 4 DBA-Schweiz).

3.10 Künstler und Sportler (Art. 16 DE-VHG)

Art. 16 DE-VHG schafft eine Spezialregelung für die Besteuerung von Künstlern und Sportlern, die gegenüber den allgemeinen Regelungen in Art. 7 DE-VHG (für selbständig tätige Künstler und Sportler) und in Art. 14 DE-VHG (für unselbständig tätige Künstler und Sportler) vorgeht. Bei Künstlern und Sportlern muss es sich um Personen handeln, die als Künstler vortragend oder darbietend selbst tätig werden oder eine sportliche Leistung selbst erbringen. Dazu gehören auch werkschaffende Künstler, die nicht selbst auftreten, wie z. B. Regisseure, Maler, Komponisten etc. und nun auch nicht-künstlerische Unterhalter wie z. B. Moderatoren. Jede Art von unterstützenden oder organisatorischen Tätigkeiten ohne eigenen Auftritt (z. B. Produzenten, Intendanten, technisches Personal etc.) fällt nicht unter Art. 16 DE-VHG.

Abs. 1 enthält die Grundregelung, der zufolge die von einem in einem Vertragsstaat ansässigen Künstler oder Sportler für seine persönlich ausgeübte Tätigkeit im anderen Vertragsstaat erhaltenen Vergütungen stets im anderen Staat besteuert werden können. Mit dieser Regelung soll das Besteuerungsrecht für diese persönlich ausgeübten Tätigkeiten stets dem Staat der Ausübung zugesprochen werden, ungeachtet etwaiger Besteuerungsschwellen, z. B. in Form einer Betriebsstätte.

Abs. 2 erweitert diese Regelung für solche Fälle, in denen dem Künstler oder Sportler die Einkünfte nicht selbst zufließen, sondern einer anderen Person, i. d. R. handelt es sich hierbei um eine vom Künstler oder Sportler selbst gegründete Verleih- bzw. Verwertungsgesellschaft.

Art. 16 Abs. 3 DE-VHG regelt das Besteuerungsrecht aus der (z. B. medialen) Verwertung der künstlerischen oder sportlichen Darbietungen und spricht dieses ebenfalls dem Ausübungsstaat zu. Eine solche Norm ist in den deutschen DBA jedoch äußerst rar, weshalb Ihnen klar sein muss, dass Einkünfte aus solchen Verwertungen i. d. R. nicht von einer DBA-Norm für Künstler und Sportler erfasst werden, weil nach Rechtsprechung Art. 16 Abs. 1 und Abs. 2 DE-VHG sich nur auf die Ausübungseinkünfte beziehen. Ebenfalls nicht von Art. 16 DE-VHG erfasst sind Einkünfte aus Transferentschädigungen und Spielerleihen (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. g EStG), weil es dort nicht um eine Tätigkeitsausübung geht, sondern um die Verwertung einer arbeitsrechtlichen Position.

Art. 16 Abs. 4 DE-VHG enthält schließlich eine Ausnahme für solche Einkünfte eines Künstlers oder Sportlers, die ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln seines Ansässigkeitsstaates stammen. In diesen Fällen soll auch das Besteuerungsrecht beim Ansässigkeitsstaat verbleiben. Eine solche Regelung ist in vielen deutschen DBA enthalten.

3.11 Ruhegehälter, Renten und ähnliche Zahlungen (Art. 17 DE-VHG)

Während die entsprechende Vorschrift in Art. 18 OECD-MA schlicht und einfach für alle Fälle dem Ansässigkeitsstaat der die Zahlung beziehenden Person das Besteuerungsrecht zuspricht, ist die Regelung für Alterseinkünfte in der DE-VHG sowie in fast allen deutschen DBA deutlich differenzierter ausgestaltet. Betroffen ist zunächst von Art. 17 DE-VHG nur die Auszahlungsphase, weshalb zur Ansparphase (siehe dazu z. B. die Regelung in Art. 14 Abs. 4 DE-VHG) keine Aussage getroffen wird. Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen für eine frühere unselbständige Arbeit oder Renten können nach der Grundregel in Abs. 1 grundsätzlich nur im Ansässigkeitsstaat der Person im Zahlungszeitpunkt besteuert werden. Ruhegehälter sind Zahlungen mit Versorgungscharakter. Der Begriff „Rente“ ist in Art. 17 Abs. 6 DE-VHG definiert. Ausgehend von dieser Grundregel haben Sie in einem Examen zu prüfen, ob eine speziellere Vorschrift besteht, die gegenüber Abs. 1 vorgeht. Nur wenn dies nicht der Fall ist, verbleibt es bei der Rechtsfolge des Abs. 1.

Art. 17 Abs. 2 DE-VHG spricht das Besteuerungsrecht speziell für Sozialversicherungsrenten (gilt auch für Leistungen der Versorgungswerke) abweichend von Abs. 1 auch dem Staat zu, gemäß dessen Sozialversicherungsrecht die Leistungen gezahlt werden. Damit wird insbesondere im Fall von im Ausland ansässigen Rentenempfängern das im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht bestehende Besteuerungsrecht (§ 49 Abs. 1 Nr. 7 EStG) gesichert.



Art. 17 Abs. 3 DE-VHG regelt ein an bestimmte Voraussetzungen geknüpftes Besteuerungsrecht des Quellenstaates für die Zahlungen i. S. v. Abs. 1. Voraussetzung dieser Vorschrift ist, dass die Leistungen zumindest teilweise auf Beiträgen beruhen, die für mindestens 15 Jahre im Quellenstaat steuerlich gefördert wurden (insbesondere durch Steuerfreiheit oder steuerliche Abziehbarkeit). Durch diese Regelung soll die nachgelagerte Besteuerung gesichert werden.

► **Beispiel:**

Der Steuerpflichtige Tomas aus Tschechien war in Deutschland unselbständig tätig. Er bezieht Alterseinkünfte aus der betrieblichen Altersvorsorge, deren Beiträge in Deutschland nach § 3 Nr. 63 EStG steuerlich gefördert wurden (nachgelagerte Besteuerung). Mit Eintritt seines Ruhestands verzieht Tomas nach Tschechien (Annahme: DBA entspricht DE-VHG), wo die vorge-lagerte Besteuerung gilt und seine Einkünfte nicht der Besteuerung unterliegen.

► **Lösung:**

Die Grundregel des Art. 17 Abs. 1 DE-VHG spricht nur Tschechien das Besteuerungsrecht zu, da Tschechien seit dem Zuzug von Tomas der Ansässigkeitsstaat ist. Dass Tomas sein gesamtes (Berufs-)Leben in Deutschland ansässig war, spielt für Abs. 1 keine Rolle. Tschechien besteuert die Leistungen gleichwohl nicht und da das DBA-Recht Schrankenrecht ist, muss Tschechien dies auch nicht. Die Leistungen blieben unversteuert, obgleich sie steuerlich gefördert wurden. Sofern die Förderung in Deutschland jedoch für mindestens 15 Jahre erfolgte, darf Deutschland nach Art. 17 Abs. 3 DE-VHG besteuern.

Nach Art. 17 Abs. 4 DE-VHG können von einem Vertragsstaat gezahlte Entschädigungen für politische Verfolgung oder aufgrund von Kriegshandlungen nur in diesem Staat besteuert werden. Schließlich regelt Art. 17 Abs. 5 DE-VHG, dass Unterhaltsleistungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, im Ansässigkeitsstaat des Empfängers grundsätzlich steuerfrei sind. Nur soweit die Zahlungen im Staat des Zahlenden steuerlich abzugsfähig sind, können sie dort besteuert werden.

3.12 Öffentlicher Dienst (Art. 18 DE-VHG)

Art. 18 DE-VHG regelt als Spezialvorschrift Zahlungen für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst. Merken Sie sich in diesem Zusammenhang bitte den Begriff „Kassenstaatsprinzip“: Leistet ein Staat bestimmte Zahlungen selbst, so ist er an der Nichtbesteuerung seiner Bediensteten mit diesen Zahlungen durch andere Staaten interessiert, weil sich insoweit der Bereich der Ausübung seiner hoheitlichen Staatstätigkeit erstreckt. Diesen Gedanken setzt Art. 18 – mit Ausnahmen – um.

Art. 18 Abs. 1 DE-VHG betrifft aktive Beschäftigungsverhältnisse und die daraus erzielten Gehälter, Löhne oder ähnliche Vergütungen, die von einem Vertragsstaat, einem seiner Länder oder einer Gebietskörperschaft für die diesem Staat, diesem Land oder der Gebietskörperschaft geleistete Dienste gezahlt werden. Das Besteuerungsrecht wird in Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 DE-VHG ausschließlich („nur“) dem Kassenstaat zugesprochen.

Eine Ausnahme vom Kassenstaatsprinzip enthält Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG für sog. „Ortskräfte“.

► **Beispiel:**

Der Ungar Sandor, der sein gesamtes Leben in Budapest lebt, ist als Sicherheitskraft an der deutschen Botschaft in Budapest, Ungarn (Annahme: DBA entspricht DE-VHG), beschäftigt. Steht Deutschland als Kassenstaat das Besteuerungsrecht zu?

► **Lösung:**

Nach dem Grundsatz des Kassenstaatsprinzips in Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 DE-VHG wäre dies zu bejahen. Nach Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG gilt allerdings die „Ortskräfte“-Regelung als Ausnahme vom Kassenstaatsprinzip, wenn die Dienste im Ansässigkeitsstaat des Zahlungsempfängers geleistet werden und der Zahlungsempfänger Staatsangehöriger dieses Staates ist (Buchst. a) sowie nicht ausschließlich deshalb in dem Staat ansässig geworden ist, um dort die Tätigkeit aufzunehmen (Buchst. b). All diese Voraussetzungen erfüllt Sandor, weshalb für seine Einkünfte das Kassenstaatsprinzip nicht greift. Es darf folglich „nur“ Ungarn besteuern.

Art. 18 Abs. 2 DE-VHG regelt in Ergänzung zu Abs. 1 das Besteuerungsrecht für Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die ein Vertragsstaat, eines seiner Länder oder eine seiner Gebietskörperschaften für geleistete Dienste zahlt und ordnet ebenfalls eine ausschließliche Besteuerung im Kassenstaat (Nr. 1) an. Auch hier greift eine Ausnahme vom Kassenstaatsprinzip, wenn die Person im anderen Staat ansässig und dessen Staatsangehöriger ist (Nr. 2).

Der Anwendungsbereich der Abs. 1 und 2 wird im Folgenden auf Leistungen an Bedienstete der Deutschen Bundesbank und der Außenhandelskammern (Abs. 3) sowie an Bedienstete des Goethe-Instituts oder des DAAD (Abs. 5) ausgedehnt.

Art. 18 Abs. 4 DE-VHG formuliert als Ausnahme zu Abs. 1 und Abs. 2 die Nichtanwendung des Kassenstaatsprinzips, wenn die Vergütungen für im Rahmen einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats geleistete Dienste gezahlt werden. Aus deutscher Sicht betrifft dies Tätigkeiten im Rahmen von Betrieben gewerblicher Art i. S. v. Art. 4 Abs. 1 Satz 1 KStG.



HINWEIS

Art. 18 DE-VHG gilt grundsätzlich unter zwei Voraussetzungen: (1) muss die Vergütungen von einem Staat, einem seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften gezahlt werden, (2) muss die Zahlung „für“ diesem Staat, diesem Land oder dieser Gebietskörperschaft geleistete Dienste gezahlt werden. Erfolgt nur die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln und wird eine Tätigkeit gegenüber einem privatrechtlichen Arbeitgeber erbracht (z. B. der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), würde die Anwendung der Norm scheitern und es käme anstelle des Kassenstaatsprinzips das Arbeitsortprinzip zur Anwendung (Art. 14 DE-VHG). Für solche Fälle fingiert § 50d Abs. 7 EStG – im Rahmen eines Treaty Override – ein Dienstverhältnis zwischen der Person und der juristischen Person des öffentlichen Rechts, aus deren Kasse die Vergütung gezahlt wird.

3.13 Gastprofessoren, Lehrer und Studenten (Art. 19 DE-VHG)

Art. 19 Abs. 1 DE-VHG enthält eine Regelung, der zufolge in einem Vertragsstaat ansässiges Lehrpersonal, das auf Einladung im anderen Staat für höchstens zwei Jahre lehrt oder forscht, im Tätigkeitsstaat nicht besteuert wird, wenn die Vergütungen nicht aus dem Tätigkeitsstaat bezogen werden. Dies betrifft z. B. vom DAAD bezahlte und ins Ausland entsandte Professoren.

Art. 19 Abs. 2 DE-VHG betrifft Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Auszubildender, der in einem Vertragsstaat ansässig ist, während seines Aufenthalts im anderen Staat für seinen Unterhalt, seine Ausbildung oder sein Studium erhält, im Aufenthaltsstaat nicht besteuert werden dürfen, wenn die Zahlungen nicht aus diesem Staat bezogen werden. Dies betrifft z. B. Auslands-Bafög deutscher Studierender oder aber Stipendien, die während eines Auslandsaufenthalts aus Deutschland bezogen werden.



3.14 Andere Einkünfte (Art. 20 DE-VHG)

Jeder Sachverhalt, der bei einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person (Art. 1 DE-VHG) zur Erhebung einer in Art. 2 DE-VHG genannten Steuer führt, ist vom Abkommenschutz erfasst. Deshalb muss für jeden erdenklichen Sachverhalt eine Einkunftsart des Abkommens einschlägig sein. Es liegt auf der Hand – zumal stets zwei Staaten potenziell besteuern –, dass der Ihnen bisher vorgestellte Katalog nicht alle denkbaren Lebenssachverhalte abdeckt. Art. 20 DE-VHG enthält daher eine Auffangregelung, die sämtliche Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person erfasst, „die in den vorstehenden Artikeln nicht behandelt wurden“. Das Besteuerungsrecht steht in diesen Fällen grundsätzlich dem Ansässigkeitsstaat zu.

Es sind insbesondere zwei Gründe denkbar, weshalb Einkünfte nicht unter die vorstehenden Verteilungsnormen fallen können. Zunächst ist dies die mangelnde sachliche Erfassung bestimmter Zahlungen. So fallen unter die „anderen Einkünfte“ u. a. Zahlungen wie Lotteriegewinne (sofern diese steuerbar sind), Entschädigungen oder Unterhaltszahlungen. Ferner kann eine Anwendung einer – sachlich einschlägigen – Verteilungsnorm aber auch an räumlichen Merkmalen scheitern. Hauptanwendungsfall der Auffangvorschrift sind daher nicht irgendwelche exotischen Sachverhalte oder Steuern, sondern der – nicht seltene – Fall rein nationaler Sachverhalte oder von Drittstaatensachverhalten im bilateralen DBA-Recht, die von einigen – explizit auf grenzüberschreitende Sachverhalte abstellenden – Verteilungsnormen nicht erfasst werden.

► **Beispiel:**

Die in Deutschland ansässige Steuerpflichtige Michaela Müller hält Anteile an Aktiengesellschaften in Deutschland und Polen. Sie fragt sich, wie die Dividenden aus diesen Anteilen nach anderen DBA, z. B. dem DBA-Österreich (Annahme: DBA entspricht DE-VHG), besteuert werden können.

► **Lösung:**

Da Michaela Müller in Deutschland ansässig ist und die Dividenden der Einkommensteuer unterliegen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5, § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG) sind der persönliche und sachliche Anwendungsbereich aller deutschen DBA erfüllt. Jedes deutsche DBA trifft somit eine Aussage zum Besteuerungsrecht an diesen Dividenden. Es erschließt sich von selbst, dass Österreich hieran kein Besteuerungsrecht zustehen soll, weil dort weder die Quelle der Einkünfte (Ansässigkeit der Gesellschaften) liegt noch ein persönlicher Bezug (Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt) besteht. Es handelt sich zwar um „Dividenden“ i. S. d. DBA (Art. 10 Abs. 3 DE-VHG), allerdings fallen diese nicht unter Art. 10 Abs. 1 und Abs. 2 DE-VHG, weil sie – aus Sicht des DBA-Österreich – zwar von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person erzielt werden, aber nicht von einer im anderen Staat ansässigen Gesellschaft gezahlt werden. Art. 10 DE-VHG erfasst wie die meisten Verteilungsnormen nur den grenzüberschreitenden Fall zwischen beiden Vertragsstaaten. Da Art. 10 DE-VHG nicht einschlägig ist, verbleibt nur die Auffangklausel in Art. 20 DE-VHG. Das Besteuerungsrecht an den Dividenden steht – aus Sicht des bilateralen Verhältnisses Deutschland/Österreich ganz logischerweise – ausschließlich Deutschland zu.

Allerdings sieht auch Art. 20 Abs. 2 DE-VHG einen – Ihnen bereits aus Art. 10 Abs. 4, Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 DE-VHG bekannten – Betriebsstättenvorbehalt vor, der dem anderen Staat als Betriebsstättenstaat ein vollumfängliches Besteuerungsrecht zuspricht, wenn die den Einkünften zugrundeliegenden Vermögenswerte tatsächlich zu der Betriebsstätte gehören.

► **Beispiel:**

Die in Deutschland ansässige X-GmbH unterhält eine Betriebsstätte in Österreich. Die Betriebsstätte erstellt Produkte, die über eine in der Slowakei ansässige Kapitalgesellschaft vertrieben werden. Wie erfolgt die Besteuerung von Dividenden dieser Kapitalgesellschaften an die X-GmbH nach dem DBA-Österreich (Annahme: DBA entspricht DE-VHG)?

► **Lösung:**

Es handelt sich um Dividenden i. S. v. Art. 10 Abs. 3 DE-VHG, die allerdings nach dem DBA-Österreich nicht zwischen beiden Vertragsstaaten gezahlt werden. Daher ist nicht Art. 10 DE-VHG, sondern Art. 20 DE-VHG einschlägig. Die Anteile an der Vertriebskapitalgesellschaft dienen jedoch der Betriebsstätten Tätigkeit und sind dieser daher tatsächlich zuzuordnen.

Daher steht Österreich als Betriebsstättenstaat nach Art. 20 Abs. 2 i. V. m. Art. 7 DE-VHG das vollumfängliche Besteuerungsrecht zu.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Andere Einkünfte in DBA – v11396

3.15 Vermögen (Art. 21 DE-VHG)

Auf eine Darstellung des Inhalts von Art. 21 DE-VHG die Besteuerung von Vermögen betreffend wird verzichtet. Die Vorschrift betrifft – nach Abschaffung der Vermögensteuer und der Gewerbesteuer – aus deutscher Sicht nur noch die Grundsteuer und ist für den Ertragsteuerteil Ihrer Prüfung nicht relevant. Wenn Sie sich die Vorschrift durchlesen, erkennen Sie einen weitgehenden Gleichlauf mit Art. 13 DE-VHG.

V. VERMEIDUNG VON DOPPELBESTEUERUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vermeidung von Doppelbesteuerung in DBA – v10864

1. Notwendigkeit der Anwendung des Methodenartikels

Nachdem über die Verteilungsnormen bestimmt worden ist, in welchen Fällen der Nicht-Ansässigkeitsstaat als Quellenstaat bestimmte Sachverhalte (auch) besteuern darf, stellt sich die Frage, ob bzw. wie die drohende Doppelbesteuerung vermieden wird. Folgende Situation kann sich nach Anwendung der Verteilungsnormen darstellen:

- Es darf nur der Ansässigkeitsstaat einen Sachverhalt besteuern (z. B. bei Unternehmensgewinnen ohne Betriebsstätte im anderen Staat, Zinsen oder Lizenzgebühren),
- Es darf nur der Nicht-Ansässigkeitsstaat einen Sachverhalt besteuern (z. B. bei Unternehmen der Schiff- oder Luftfahrt i. S. d. Art. 8 DE-VHG mit Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens in diesem Staat),
- Es dürfen der Nicht-Ansässigkeitsstaat, aber auch der Ansässigkeitsstaat besteuern (z. B. unbewegliches Vermögen im anderen Staat, Unternehmensgewinne mit Betriebsstätte im anderen Staat, Dividenden oder Einkünfte aus im anderen Staat ausgeübter unselbständiger Tätigkeit).

Nur der letztgenannte Fall erfordert eine weitere Anwendung des DBA, um Doppelbesteuerung zu vermeiden: Die Anwendung des Methodenartikels. Der Name „Methodenartikel“ wird verwendet, weil diese Vorschrift anordnet, ob die Freistellungs- oder Anrechnungsmethode zur Anwendung kommt. Den Methodenartikel wendet stets nur der Ansässigkeitsstaat an! Diesem obliegt die Vermeidung von Doppelbesteuerung.



2. Grundfall: Freistellung unter Progressionsvorbehalt

In fast allen deutschen DBA (Ausnahme z. B. das DBA-Zypern) ist als Grundsatz die Freistellungsmethode verankert. Freistellung meint das „Ausnehmen“ von Einkünften aus der deutschen Bemessungsgrundlage. Damit entspricht die Freistellung einer sachlichen Steuerbefreiung, wie § 3 EStG sie anordnet. Die grundsätzlich steuerbaren Einkünfte (sowohl die positiven als auch die negativen) werden dann von der deutschen Steuer ausgenommen und nicht besteuert. Typischerweise gilt die Freistellung jedenfalls für im anderen Staat besteuertes unbewegliches Vermögen, ausländische Betriebsstättengewinne, Schachteldividenden und Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit. Technisch ordnet ein DBA die Freistellung als Grundsatz an (siehe z. B. Art. 22 Abs. 1 Nr. 1 DE-VHG „Soweit Nr. 3 nichts anderes vorsieht, [...]“ und durchbricht diesen dann punktuell.

Die Freistellung erfolgt unter Progressionsvorbehalt auf Grundlage von § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG. Das bedeutet, Sie erfassen die steuerfreien Einkünfte zunächst doch, um auf Basis aller (steuerpflichtigen und steuerfreien) Einkünfte den Steuersatz nach § 32a Abs. 1 EStG zu ermitteln. Die steuerfreien DBA-Einkünfte werden folglich zur Ermittlung des besonderen Steuersatzes den steuerpflichtigen Einkünften hinzugerechnet (§ 32b Abs. 2 EStG).

► **Beispiel:**

Der in Deutschland ansässige Steuerpflichtige Walther Weiß hat in Polen investiert. Er erzielt Einkünfte aus der Vermietung einer Immobilie in Polen sowie Einkünfte aus einem polnischen Produktionsbetrieb, in dem Gartenmöbel hergestellt werden. Wie erfolgt die steuerliche Berücksichtigung der Einkünfte nach dem DBA-Polen (Annahme: DBA entspricht DE-VHG)?

► **Lösung:**

Die Vermietungseinkünfte können nach Art. 6 Abs. 1 DE-VHG und die Unternehmensgewinne nach Art. 7 Abs. 1 DE-VHG wegen der polnischen Betriebsstätte (Art. 5 Abs. 2 Nr. 4 DE-VHG) in Polen besteuert werden. Beide Arten von Einkünften werden nach Art. 22 Abs. 1 Nr. 1 DE-VHG von der Besteuerung ausgenommen (also freigestellt), weil die Produktionsgewinne auch die Voraussetzungen des Aktivitätsvorbehalts (dazu auch nächster Abschnitt) nach Art. 22 Abs. 1 Nr. 4 DE-VHG erfüllt. Nach Art. 22 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG kann Deutschland diese Einkünfte bei der Festsetzung des Steuersatzes berücksichtigen (Progressionsvorbehalt). Allerdings ist nun § 32b Abs. 1 Satz 2 EStG zu beachten, der eine Ausnahme vom Progressionsvorbehalt aufstellt. Dort werden bestimmte (als passiv eingestufte) Einkünfte genannt, bei denen der Progressionsvorbehalt in EU/EWR-Fällen („anderen als in einem Drittstaat“) ausgeschlossen wird. Da Polen kein Drittstaat i. S. v. § 2a Abs. 2a EStG i. V. m. § 32b Abs. 1 Satz 3 EStG ist, wird auf Einkünfte aus der Vermietung unbeweglichen Vermögens kein Progressionsvorbehalt angewendet (§ 32b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG). Auch bei Einkünften aus gewerblichen Betriebsstätten in einem EU/EWR-Staat wird in bestimmten Fällen der Progressionsvorbehalt ausgeschlossen (§ 32b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG). Vorliegend verbleibt es jedoch bei Anwendung des Progressionsvorbehalts, weil die Produktion eine aktive Tätigkeit i. S. v. § 2a Abs. 2 Satz 1 EStG ist (keine Waffenproduktion), vgl. § 32b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG.

Wenn Sie sich nun fragen, wieso der Gesetzgeber sich entschieden hat, in einigen Fällen auf Anwendung des Progressionsvorbehalts zu verzichten, so ist dies keineswegs als Begünstigung der Steuerpflichtigen mit nämlichen Einkünften gedacht.

► **Beispiel:**

Der in Deutschland ansässige Steuerpflichtige Walther Weiß erzielt nun in Deutschland steuerpflichtige Arbeitnehmereinkünfte i. H. v. 30.000 Euro. Zusätzlich hat er sich an einem größeren Immobilienprojekt in Polen beteiligt, aus dem in der Anlaufphase negative Einkünfte i. H. v. 30.000 Euro auf ihn entfallen.

► **Lösung:**

Die Vermietungseinkünfte können nach Art. 6 Abs. 1 DE-VHG in Polen besteuert werden. Das gilt auch für negative Einkünfte. Diese negativen Einkünfte werden auch nach Art. 22 Abs. 1 Nr. 1 DE-VHG von der Besteuerung ausgenommen. Nach Art. 22 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG kann Deutschland diese Einkünfte bei der Festsetzung des Steuersatzes berücksichtigen (Progressionsvorbehalt). Würde Deutschland dies tun, so würden die ausländischen, steuerfreien Einkünfte für die Ermittlung des Steuersatzes den inländischen, steuerpflichtigen Einkünften hinzugerechnet (§ 32b Abs. 2 EStG). Der Steuersatz würde dann auf den Betrag von 0 Euro (30.000 Euro - 30.000 Euro) ermittelt werden und ebenfalls 0 % betragen! Walther Weiß hätte folglich durch den negativen Progressionsvorbehalt einiges an Steuern gespart.

Durch die Ausnahmeregelungen in § 32b Abs. 1 Satz 2 EStG (bitte Katalog lesen, verstehen und markieren!) soll solchen Situationen vorgebeugt werden. Da innerhalb des Anwendungsbereichs der europäischen Grundfreiheiten (EU/EWR-Raum) nach Rechtsprechung des EuGH positive und negative Einkünfte gleich zu behandeln sind (sog. Symmetriethese), musste der deutsche Gesetzgeber in diesen Fällen auch auf Anwendung des positiven Progressionsvorbehalts verzichten.

► **Beispiel:**

Der in Deutschland ansässige Steuerpflichtige Walther Weiß hat weiterhin in Polen investiert: Nun beteiligt er sich (als Mitunternehmer) an einem polnischen Schifffahrtsunternehmen, das in den Masuren touristische Tagestouren organisiert. Wie erfolgt die steuerliche Berücksichtigung der Einkünfte nach dem DBA-Polen (Annahme: entspricht der DE-VHG)?

► **Lösung:**

Die geographisch Versierten unter Ihnen wissen, dass die Masuren ein Seengebiet innerhalb Polens sind. Es handelt sich folglich um den Betrieb von Binnenschifffahrt. Die daraus erzielten Gewinne können nach Art. 8 Abs. 2 DE-VHG nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Nehmen wir an, das polnische Unternehmen hat seine tatsächliche Geschäftsleitung in Polen, so kann „nur“ Polen besteuern. Wenn Sie dieses Modul aufmerksam gelesen haben, dann wissen Sie, dass Deutschland als Ansässigkeitsstaat den Methodenartikel – und damit auch Art. 22 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG, der auf den Progressionsvorbehalt verweist – nicht mehr anwendet. Die Freistellung ergibt sich bereits nach Anwendung der Verteilungsnorm. Dies bedeutet gleichwohl nicht, dass Deutschland keinen Progressionsvorbehalt mehr anwenden darf. Der BFH geht davon aus, dass die Ermächtigung in Art. 22 Abs. 1 Nr. 2 DE-VHG rein klarstellend – und damit eine fehlende Ermächtigung unschädlich – ist!

3. Anrechnungsmethode

Ausgehend und abweichend vom Grundsatz der Freistellungsmethode wird in den Methodenartikeln der deutschen DBA für bestimmte Einkünfte bzw. Sachverhalte die Anrechnungsmethode vereinbart. Die Anrechnungsmethode kennen Sie bereits aus dem nationalen Recht (Modul IStR 01). Verweist das DBA auf die Anrechnung ausländischer Steuern, so gilt dies nach § 34c Abs. 6 Satz 2 EStG als Spezialvorschrift: Sie müssen dann nicht mehr die Voraussetzungen der Anrechnung nach § 34c Abs. 1 Satz 1 EStG prüfen, sondern können unmittelbar die Anrechnung der Höhe nach (§ 34c Abs. 1 Satz 2 bis 5 EStG) berechnen. In deutschen DBA ist die Anrechnungsmethode i. d. R. dann vorgesehen, wenn Einkünfte nur der Höhe nach begrenzt im anderen Staat besteuert werden können, das heißt bei Einkünften i. S. d. Art. 10 bis 12 DE-VHG, außerdem oftmals bei Tätigkeiten ohne dauerhafte Verbindung zum Ausland, z. B. als Aufsichts- oder Verwaltungsrat (Art. 15 DE-VHG) oder Künstlern und Sportlern (Art. 16 DE-VHG).



HINWEIS

Bitte denken Sie stets daran, alle Aufzählungen und Beispiele, die Sie in diesem Modul lesen, entbinden Sie in einer Prüfungssituation nicht davon, das konkrete DBA genauestens zu prüfen. Es ist stets möglich, dass dort auch für andere Einkünfte die Freistellung oder Anrechnung ausländischer Steuern vorgesehen wird als es hier geschildert wird!

Wichtiger als die bloße Aufzählung von Einkünften, die der Anrechnung unterliegen, sind jedoch die (Vielzahl an) Normen, die die Freistellungsmethoden flankieren und für bestimmte Sachverhalte abweichend vom Grundsatz der Freistellung die Anrechnungsmethode anordnen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht an Klauseln, denen diese Eigenschaft zukommen kann:

- Einschränkungen des Schachtelprivilegs (Art. 22 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 DE-VHG) in Fällen von Gewinnausschüttungen steuerbefreiter Gesellschaften, insbesondere aufgrund von Einordnungskonflikten (hybride Gesellschaften oder Finanzinstrumente) (Alt. 1), bei Abziehbarkeit der Gewinnausschüttung bei der ausschüttenden Gesellschaft (Alt. 2) oder bei Zurechnungskonflikt (Alt. 3).
- Aktivitätsklauseln (Art. 22 Abs. 1 Nr. 4 DE-VHG) beschränken die Freistellung von Betriebsstätteninkünften (Art. 7 Abs. 1, Art. 13 Abs. 2 DE-VHG) und Schachteldividenden (Art. 10 DE-VHG) auf Fälle, in denen im Ausland eine „aktive“ Tätigkeit ausgeübt wird. Was aktiv ist, wird entweder – wie in der DE-VHG – im Abkommen selbst definiert. In vielen deutschen DBA wird schlicht auf den Aktivitätskatalog in § 8 Abs. 1 AStG in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des DBA (kein dynamischer Verweis!) geltenden Fassung (oftmals nur auf die Nummern 1 bis 6) verwiesen. Die Vorschriften des AStG werden in Lehrbrief IStR 03 vorgestellt.
- Umschalt- bzw. Switch-over-Klauseln (Art. 22 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a DE-VHG) sehen ein „Umschalten“ (also einen Wechsel) von Freistellung auf Anrechnung vor, wenn ein sog. Qualifikationskonflikt vorliegt, d. h. beide Staaten von der Anwendung unterschiedlicher Vorschriften im DBA ausgehen und sich daraus eine Doppelbesteuerung (beide Staaten wollen vollumfänglich besteuern) oder Minderbesteuerung (beide Staaten wollen nicht vollumfänglich besteuern) ergibt.
- Rückfall- bzw. Subject-to-tax-Klauseln (Art. 22 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b DE-VHG) machen die Freistellung von Einkünften von der tatsächlichen Besteuerung im anderen Staat abhängig. Nimmt der andere Staat das ihm abkommensrechtliche Besteuerungsrecht nicht wahr, so fällt das Besteuerungsrecht an Deutschland zurück (Rückfall) und Deutschland besteuert die Einkünfte. Bitte beachten Sie, solche Subject-to-tax-Klauseln können auch im Verteilungsartikel „versteckt“ sein (so z. B. Art. 15 Abs. 4 DBA-Österreich).

Die Anwendung dieser Klauseln ist ausführlich im BMF-Schreiben vom 20.6.2013, BStBl 2013 I S. 980 erläutert.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorbehalte zur DBA-Freistellung – v10865

VI. PROTOKOLL

Wir möchten an dieser Stelle (fast) keine inhaltlichen Ausführungen zum Protokoll der DE-VHG machen. Die Protokolle der deutschen DBA sind nicht einheitlich, sondern unterscheiden sich im Einzelfall. Wir möchten aber noch einmal grundsätzlich an Sie appellieren, das Protokoll stets im Kopf zu haben und es wenigstens einmal zu überfliegen, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen. Vielfach finden sich dort z. B. Ausführungen, wenn es um partiarische Darlehen oder stille Beteiligungen geht, bei denen die Abgrenzung zwischen Art. 10 und Art. 11 besonders problematisch ist, oder aber bezüglich der Besteuerung im Rahmen von Subject-to-tax-Klauseln. Versuchen Sie bitte, an unseren Hinweis zu denken!

VII. TREATY OVERRIDE



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Treaty Override – v10866

1. Arten von Treaty Override

Wir haben bisher gelernt, dass das Abkommensrecht auch als „Schrankenrecht“ bezeichnet wird, weil es die nationalen Besteuerungsansprüche einschränkt. Das DBA-Recht geht deshalb grundsätzlich gegenüber dem nationalen Recht vor (§ 2 Abs. 1 AO). Treaty Override sind dagegen für den Ausnahmefall – für besondere vom Gesetzgeber identifizierte Probleme – geschaffene nationale Vorschriften, die darauf ausgerichtet sind, DBA-Vorschriften unilateral zu überschreiben. Dies wird in der Regel durch die Anordnung bestimmter Rechtsfolgen „ungeachtet des Abkommens“ oder „ungeachtet der Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung“ kenntlich gemacht. Es gibt aber auch Klauseln, die diese Formulierung nicht enthalten, aber dennoch als Treaty Override bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um Regelungen, mit denen der Gesetzgeber den Gerichten eine bestimmte Abkommensauslegung – entgegen der früheren Rechtsprechung – vorschreibt (§ 50d Abs. 7, Abs. 10, Abs. 12 EStG).

Die bestehenden Treaty Override werden nach drei Zielrichtungen unterschieden: So gibt es Treaty Override zur Vermeidung von Keinmal- oder Minderbesteuerung (z. B. § 50d Abs. 8, Abs. 9 EStG), Treaty Override zur Vermeidung von Missbrauch (§ 50d Abs. 3, § 50j EStG) und Treaty Override zur Sicherung des Besteuerungssubstrats (§ 50d Abs. 7, Abs. 10, Abs. 12 EStG).



HINWEIS

Natürlich müssen Sie in einer Prüfungslösung nicht die Zielrichtung eines Treaty Override benennen. Gleichwohl kann die Kenntnis der drei Ziele von Treaty Override sowie der dazugehörigen Vorschriften eine große Hilfe beim Erkennen von Problemen in der Aufgabenstellung sein. Findet sich in der Aufgabentext der Hinweis, dass bestimmte Einkünfte aus selbständiger Arbeit im DBA-Ausland, dem das Besteuerungsrecht nach dem DBA zustand, nicht deklariert wurden, so muss Ihnen bewusst sein, dass § 50d Abs. 8 EStG hier genauestens zu prüfen ist. Wird dagegen in einem DBA-Sachverhalt ein Mitunternehmer behandelt, so führt die Lösung mit Sicherheit über § 50d Abs. 10 EStG.



Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine abschließende Übersicht über Treaty Override im EStG und KStG. Das GewStG enthält derzeit (noch) keine Treaty Override!

Fundstelle	Regelungsgegenstand
§ 4j EStG	Abzugsbeschränkung für im Ausland einer Vorzugsbesteuerung unterliegende Lizenzaufwendungen an verbundene Unternehmen
§ 4k EStG	Abzugsbeschränkung bei hybriden Gestaltungen
§ 15 Abs. 1a EStG	Sicherung des Besteuerungsrechts für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer Europäischen Gesellschaft oder einer Europäischen Genossenschaft, bei deren vorheriger Sitzverlegung eine Entnahmebesteuerung wegen § 4 Abs. 1 Satz 5 EStG ausblieb
§ 17 Abs. 5 Satz 3 EStG	Sicherung des Besteuerungsrechts für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, bei deren vorheriger Sitzverlegung eine Besteuerung wegen § 17 Abs. 5 Satz 1 EStG ausblieb
§ 20 Abs. 4a EStG	Sicherung des Besteuerungsrechts für Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaften, die durch steuerneutralen Anteilstausch erworben wurden
§ 48d Abs. 1 EStG	Verpflichtung zur Vornahme von Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Bauabzugsteuer auch in DBA-Fällen
§ 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG	Beschränkte Steuerpflicht für Einkünfte aus umgekehrt hybriden Personengesellschaften
§ 50c Abs. 1 Satz 1 EStG	Verpflichtung zur Vornahme von Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Kapitalertragsteuer oder der Steuer nach § 50a EStG auch in DBA-Fällen
§ 50d Abs. 3 EStG	Versagung der Entlastung von Quellensteuern zur Vermeidung von Steuerumgehung
§ 50d Abs. 7 EStG	Vorgaben zur Auslegung der DBA-Vorschrift über den öffentlichen Dienst (entsprechend Art. 18 DE-VHG) bezüglich mittelbarer Dienstverhältnisse mit der öffentlichen Hand
§ 50d Abs. 8 EStG	Verknüpfung der DBA-Freistellung von Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit mit dem Nachweis, dass die Einkünfte im anderen Staat besteuert wurden oder der andere Staat auf die Besteuerung verzichtet hat
§ 50d Abs. 9 Satz 1 EStG	Umschaltklausel (Übergang von Freistellung zur Anrechnung), soweit aufgrund eines Qualifikationskonfliktes eine Minderbesteuerung eintritt (Nr. 1) oder der andere Staat bestimmte Einkünfte im Rahmen seiner beschränkten Steuerpflicht nicht erfasst (Nr. 2)
§ 50d Abs. 9 Satz 4 EStG	Vorgaben zur Auslegung von die Freistellung betreffenden DBA-Vorschriften
§ 50d Abs. 10 EStG	Durchführung des Mitunternehmerkonzeptes in DBA-Fällen
§ 50d Abs. 11 EStG	Versagung des DBA-Schachtelprivilegs bei hybriden Kapitalgesellschaften als Empfänger der Dividenden

Fundstelle	Regelungsgegenstand
§ 50d Abs. 12 EStG	Vorgaben zur Auslegung der DBA-Vorschrift über unselbstständige Arbeit (entsprechend Art. 14 DE-VHG) bezüglich Abfindungszahlungen
§ 50d Abs. 13 EStG	Gleichstellung von Dividendenkompensationszahlungen mit Dividenden für Zwecke der DBA-Anwendung
§ 50d Abs. 14 EStG	Beschränkung der Entlastung von deutscher Kapitalertragsteuer für ausländische Gesellschafter einer nach § 1a KStG optierenden Gesellschaft bei abweichender Zurechnung im Ausland
§ 50i Abs. 1 EStG	Sicherung des Besteuerungsrechts für Gewinne aus Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens oder aus Anteilen i. S. v. § 17 EStG, die vor dem 29.6.2013 in das Betriebsvermögen einer Personengesellschaft i. S. v. § 15 Abs. 3 EStG übertragen oder überführt wurden oder die aufgrund einer Betriebsaufspaltung zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören
§ 50j EStG	Versagung der Entlastung von Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge i. S. v. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG in Fällen von Cum/Cum treaty shopping (Parallelvorschrift zu § 36a EStG)
§ 8b Abs. 1 Satz 3 KStG	Durchsetzung des Korrespondenzprinzips in § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG auch in DBA-Fällen

Weitere Treaty Override (aus dem Bereich des AStG) werden Sie in Lehrbrief IStR 03 kennenlernen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Treaty Override bei Minderbesteuerungen – v11400



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Treaty Override zur Sicherung von Steuersubstrat – v11401



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Treaty Override zur Missbrauchsvermeidung – v11402

2. Darstellung ausgewählter Treaty Override anhand von Beispielsfällen

Für **Lizenzaufwendungen**, die nach dem 31.12.2017 entstehen, sieht § 4j EStG ein (Teil-)Abzugsverbot vor, wenn der Gläubiger, also der Zahlungsempfänger, im Ausland einer Vorzugsbesteuerung unterliegt und es sich um eine nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 2 AStG handelt. Durch diese Regelung soll schädlicher Steuerwettbewerb unterbunden werden.



► **Beispiel:**

Der XY-Konzern hat seine immateriellen Rechte auf die XY-S. a. r. l. in Luxemburg übertragen, die dort einer Patentbox-Besteuerung in Höhe von 5 % unterliegt. Auch die inländische XY-GmbH, eine Schwestergesellschaft (nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 2 AStG) zahlt der Höhe nach angemessene (also fremdübliche) 100.000 Euro Lizenzgebühr an die S. a. r. l.

► **Lösung:**

Die S. a. r. l. unterliegt in Luxemburg einer Patentbox, also einer Vorzugsbesteuerung für Einnahmen aus immateriellen Rechten. Wenn annahmegemäß die luxemburgische Regelung nicht an den Vorgaben der OECD ausgerichtet ist (sonst würde nach § 4j Abs. 1 Satz 4 EStG eine Ausnahme von § 4j EStG greifen), sind die Voraussetzungen des § 4j Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 EStG erfüllt. Es würde dann ein Teilabzugsverbot beim Lizenzschuldner nach § 4j Abs. 3 Satz 1 EStG greifen: $66,67\% \text{ der Lizenzaufwendungen } [(15\% - 5\%) / 15\% = 66,67\%]$, also 66.667 Euro wären dann nicht abziehbar. Um abkommensrechtlichen Beschränkungen vorzubeugen, wird in § 4j Abs. 1 Satz 1 EStG angeordnet, dass die Vorschrift „ungeachtet eines bestehenden Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung“ gilt. § 4j EStG geht deshalb jedenfalls den DBA vor und wird nicht gesperrt.

§ 50c Abs. 1 Satz 1 EStG regelt den Grundsatz des fortbestehenden Quellensteuerabzugs. Sie haben in Modul IStR 01 Entlastungen von Quellensteuern in Gestalt von § 43b EStG oder § 50g EStG kennengelernt. In diesem Modul haben Sie kennengelernt, dass auch nach Art. 10 Abs. 2 DE-VHG Quellensteuern auf Dividenden der Höhe nach begrenzt werden. Nach dem Willen des Gesetzgebers dürfen solche Ansprüche aber nicht dazu führen, dass der Schuldner der Zahlungen von vornherein keine Steuer einbehält. Daher ordnet § 50c Abs. 1 Satz 1 EStG an, dass die Quellensteuern jedenfalls zunächst einzubehalten, abzuführen und anzumelden sind.

► **Beispiel:**

Die Cheese Steak Corp. (entspricht einer deutschen AG) aus Philadelphia, USA, ist seit einigen Jahren unmittelbar zu 15 % an einer inländischen AG beteiligt und erhält von dieser eine Dividende.

► **Lösung:**

Nach 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG muss die inländische AG Kapitalertragsteuer i. H. v. 25 % (§ 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) einbehalten. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a DBA-USA begrenzt die Höhe der Quellensteuern zwar auf 5 %, die inländische AG kann sich jedoch ausnahmsweise – trotz Schrankenwirkung des DBA – nicht auf diese Abkommensnorm berufen, um von vornherein eine niedrigere Quellensteuer einzubehalten, § 50c Abs. 1 Satz 2 EStG. Stattdessen ist grundsätzlich die Steuer in voller Höhe einzubehalten (§ 50c Abs. 1 Satz 1 EStG) und später von der Corp. Eine Erstattung zu beantragen, § 50c Abs. 1 Satz 2 ff. EStG. Nur wenn die Corp. bereits im Voraus eine Freistellungsbescheinigung i. S. v. § 50c Abs. 2 EStG beantragt hätte und diese im Ausschüttungszeitpunkt der inländischen AG vorläge, dürfte auf einen Einbehalt teilweise verzichtet werden.

§ 50d Abs. 3 EStG schränkt die sich aus den in § 43b bzw. § 50g EStG umgesetzten EU-Richtlinie oder aus einem DBA ergebende Vorteile ein (die Norm gilt entsprechend in Fällen des § 44a Abs. 9 EStG), wenn die Vorteile durch Gestaltungen künstlich herbeigeführt werden. Die Vorschrift hat in der Praxis große Bedeutung und wurde jüngst reformiert, was einen Aufgabensteller einladend könnte.

► **Beispiel:**

Der Jordanier Achmad will sich an der deutschen X-GmbH zu 15 % beteiligen. Er fürchtet jedoch die deutschen Quellensteuern auf Gewinnausschüttungen und sucht nach Möglichkeiten, diese zu umgehen. Er hat vom Steuerstandort Großbritannien gehört, der sich als Holdingstandort eignet und keine Quellensteuern auf Gewinnausschüttungen erhebt. Achmad gründet daher in Großbritannien eine Holding Ltd., deren Anteile er alleine hält und die sich

zu 15 % an der X-GmbH beteiligt. Die Holding Ltd. geht keiner Wirtschaftstätigkeit nach, sondern hält einzig die Beteiligung an der X-GmbH. Die X-GmbH tätigt eine Gewinnausschüttung.

► **Lösung:**

Die Dividende wird von der deutschen GmbH an die britische Holding gezahlt. Es handelt sich um eine „Dividende“ i. S. v. Art. 10 Abs. 3 DBA-Großbritannien. Da die Ltd. zu 15 % an der X-GmbH beteiligt ist, kann die deutsche Steuer auf 5 % reduziert werden (Art. 10 Abs. 2 Buchst. a DBA-Großbritannien). Wie Sie wissen, kann diese Entlastung entweder durch spätere Erstattung (§ 50c Abs. 3 EStG) oder vorab durch Beantragung einer Freistellungsbescheinigung (§ 50d Abs. 2 EStG) erreicht werden. In beiden Fällen ist § 50d Abs. 3 EStG zu prüfen, der eine Vorschrift zur Bekämpfung ungerechtfertigter Steuerumgehungen vorsieht. Nach § 50d Abs. 3 EStG erfolgt eine mehrstufige Prüfung: 1) wird der Entlastungsanspruch nicht versagt, wenn den Gesellschaftern dieser Entlastungsanspruch selbst zustünde. Achmad würde bei unmittelbarer Beteiligung an der GmbH kein Entlastungsanspruch zustehen, weshalb diese persönliche Entlastungsberechtigung nicht erfüllt ist. 2) wird der Entlastungsanspruch ebenfalls nicht versagt, soweit die Einkunftsquelle (also die Beteiligung) einen wesentlichen Zusammenhang mit einer Wirtschaftstätigkeit dieser ausländischen Körperschaft aufweist. Dies ist vorliegend ebenfalls nicht erfüllt, weil die Holding Ltd. keiner Wirtschaftstätigkeit nachgeht. Es verbleibt die Möglichkeit des Nachweises durch die ausländische Körperschaft, dass deren Einschaltung nicht als Hauptzweck der Erzielung steuerlicher Vorteile dient. Scheitert dieser Nachweis, so ist die Entlastung nach § 50c EStG zu versagen.

§ 50d Abs. 8 Satz 1 EStG adressiert das Problem, dass Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG), die nach einem DBA im anderen Staat besteuert werden können, wobei Deutschland diese Einkünfte freistellt, im anderen Staat Steuerverkürzung betreiben können. Gedacht wurde bei der Vorschrift insbesondere an Steuerpflichtige, die sich im anderen Staat nicht dauerhaft aufhalten (z. B. Piloten, Berufskraftfahrer) und von deren der andere Staat nur schwer Kenntnis erlangt. Gleichwohl wurde die Vorschrift nicht auf solche Steuerpflichtigen beschränkt, sondern betrifft alle Arbeitnehmer mit nach DBA freigestellten Einkünften. Diese müssen einen Nachweis über die Besteuerung oder den Besteuerungsverzicht des anderen Staates erbringen. Einzelheiten des Nachweises sind in BMF, Schreiben v. 21.7.2005, BStBl. 2005 I, S. 821, Beck'sche Steuererlasse 1 § 50d/2, geregelt.

► **Beispiel:**

Die unbeschränkt steuerpflichtige Yasmin ist aufgrund ihrer vielfältigen Sprachkenntnisse für mehr als 183 Tage im betreffenden Steuerjahr in Iran unselbständig tätig. Laut ihrem Arbeitsvertrag unterliegen ihre Einkünfte einem Steuerabzug in Iran. Yasmin legt dem Finanzamt ihren Arbeitsvertrag vor, erbringt darüber hinaus aber keine Nachweise bezüglich der steuerlichen Behandlung in Iran.

► **Lösung:**

Yasmin erzielt nach dem DBA-Iran Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, die wegen Art. 15 Abs. 1 in Iran besteuert werden können und in Deutschland nach Art. 24 Abs. 1 Buchst. a DBA-Iran freigestellt werden. Allerdings gilt diese Freistellung nach § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG nur unter dem Vorbehalt der Nachweiserbringung. Ein solcher Nachweis wird nicht durch bloße Vorlage eines Arbeitsvertrags geführt.

Zwar wird im Ausnahmefall eine Arbeitgeberbescheinigung anerkannt, wenn der Arbeitslohn im Ausland einem abgeltenden Steuerabzug unterliegt, allerdings muss dann auch die Höhe der Steuer und der Einkünfte bescheinigt werden (BMF, Schreiben v. 21.7.2005, BStBl. 2005 I, S. 821, Tz. 2.1.2). Letzteres ist jedenfalls nicht erfüllt, weshalb die Freistellung wegen § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG versagt wird. Zu beachten ist für solche Fälle allerdings § 50d Abs. 8 Satz 2 EStG, der eine eigenständige Änderungsvorschrift im Falle einer späteren Nachweiserbringung vorsieht, die zeitlich keine zeitliche Beschränkung vorsieht!



§ 50d Abs. 9 Satz 1 EStG enthält eine Umschaltklausel, die in bestimmten Fällen einen Übergang von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode vorsieht. Dann sind § 34c Abs. 1 bis 3 EStG entsprechend anzuwenden, § 34c Abs. 6 Satz 5 EStG.

► **Beispiel:**

Der inländische Steuerpflichtige Hans Wurst ist Mitunternehmer einer gewerblich tätigen Personengesellschaft mit einziger Produktionsbetriebsstätte in Antwerpen (Belgien). Er gibt der Personengesellschaft ein Darlehen und erhält hierfür Zinsen, die in Belgien als Kapitaleinkünfte angesehen werden.

► **Lösung:**

Legt Belgien das DBA-Belgien autonom aus, so wird es vom Vorliegen von „Zinsen“ i. S. v. Art. 11 Abs. 4 DBA-Belgien ausgehen und ein der Höhe nach auf 15 % beschränktes Besteuerungsrecht annehmen. Deutschland stellt die Zinsen (Sondervergütungen) als ausländischen Betriebsstättengewinn wegen § 50d Abs. 10 EStG (dazu sogleich) aber frei, vgl. Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 DBA-Belgien. Es besteht eine Minderbesteuerung (sog. „graue Einkünfte“), weil die Einkünfte in Deutschland gar nicht und in Belgien begrenzt besteuert werden. Da diese Minderbesteuerung aus einer – aus deutscher Sicht – abweichenden Abkommensanwendung (Qualifikationskonflikt) resultiert, greift § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 EStG und ordnet ein „Umschalten“ von Freistellung zu Anrechnung an.

► **Beispiel:**

Der inländische Steuerpflichtige Peter Popp-Ei ist „Seemann“ und als solcher auf einem Seeschiff, welches unter der Flagge Maltas fährt, für ein Unternehmen mit tatsächlicher Geschäftsleitung auf Zypern tätig. Zypern besteuert nach nationalem Steuerrecht Einkünfte, die auf einem nicht auf Zypern registrierten Schiff erzielt werden, nur bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, nicht jedoch bei beschränkt Steuerpflichtigen.

► **Lösung:**

Es handelt sich um Einkünfte aus unselbständiger Arbeit i. S. d. DBA-Zypern, welche nach Art. 14 Abs. 4 DBA-Zypern „nur“ in Zypern besteuert werden können, weil sich dort der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Deutschland stellt die Einkünfte frei. Zwar sieht das DBA-Zypern im Methodenartikel ausschließlich die Anrechnungsmethode vor, gleichwohl ist vorliegend eine sog. „abschließende Verteilungsnorm“ einschlägig, die Deutschland eine Besteuerung verbietet. Da auch Zypern nicht besteuert, handelt es sich um nicht besteuerte Einkünfte (sog. „weiße Einkünfte“). Da es sich um Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit i. S. d. § 19 EStG handelt, ist zunächst § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG zu beachten (siehe dazu bereits oben), der allerdings nicht anwendbar ist, weil Zypern die Einkünfte kennt und freiwillig – aufgrund der Ausgestaltung des Katalogs beschränkt steuerpflichtiger Einkünfte – nicht besteuert, liegt jedoch ein unschädlicher Verzicht i. S. d. § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG vor. Allerdings ist § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG einschlägig: Wäre Popp-Ei in Zypern unbeschränkt steuerpflichtig, würde er besteuert werden. Er wird dies dagegen „nur deshalb“ nicht, weil er in Zypern nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist. Genau diese „Lücke“ will § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG schließen und ordnet für diesen Fall wiederum eine Versagung der Freistellung und einen Übergang zur Anrechnung an.

§ 50d Abs. 10 EStG geht auf langjährige Rechtsprechung des BFH zur Anwendung des Mitunternehmerkonzeptes im Abkommensrecht zurück. Es handelt sich um ein Nichtanwendungsge-
setz, das sich gegen eine abkommensautonome Auslegung durch die BFH-Rechtsprechung richtet. Die Norm schreibt für Sondervergütungen vor, dass diese – sofern nicht das DBA bereits eine explizite Regelung enthält – für Zwecke der DBA-Anwendung ausschließlich Unternehmensgewinne sind (Satz 1) und zwingend der Personengesellschafts-Betriebsstätte zuzuordnen sind (Satz 3), wie dies im rein nationalen Sachverhalt geschieht.

► **Beispiel:**

Der in Polen wohnhafte Steuerpflichtige Jacek ist Mitunternehmer einer gewerblich tätigen KG mit einziger Produktionsbetriebsstätte in Berlin (Deutschland). Er gibt der KG ein Darlehen und erhält hierfür Zinsen.

► **Lösung:**

Sobald Sie in einem DBA-Sachverhalt einen Mitunternehmerfall zu lösen haben, müssen Sie § 50d Abs. 10 EStG denken. Die Vorschrift ist in diesen Fällen grundsätzlich zu beachten, wenn nicht das DBA selbst eine „solche Vergütungen betreffende ausdrückliche Regelung enthält“ (§ 50d Abs. 10 Satz 1 EStG). Wichtige DBA, die eine solche Regelung (jeweils in Art. 7 Abs. 7) enthalten, und für die § 50d Abs. 10 EStG daher nicht greift, sind das DBA-Österreich und das DBA-Schweiz. Das DBA-Polen gehört nicht dazu. Nach Rechtsprechung des BFH handelt es sich um „Zinsen“ i. S. d. Art. 11 Abs. 4 DBA-Polen, der gegenüber Art. 7 DBA-Polen (Unternehmensgewinne) aufgrund des Spezialitätsgrundsatzes vorgeht. Sie erinnern sich, hoffentlich, an den Betriebsstättenvorbehalt in Art. 11 Abs. 5 DBA-Polen (Art. 11 Abs. 3 DE-VHG), der unter gewissen Umständen auf Art. 7 zurück verweist, wenn der Vermögenswert (die Forderung) tatsächlich zur Betriebsstätte gehört. Genau dies negiert der BFH jedoch in ständiger Rechtsprechung, weil die Forderung aus Sicht der Personengesellschaft gar keine Forderung, sondern eine Verbindlichkeit ist (die korrespondierende Bilanzierung ist im DBA-Recht nicht verankert!). Es bleibt nach Ansicht des BFH daher bei einer Anwendung von Art. 11 DBA-Polen und Deutschland darf als Quellenstaat nur 5 % der Zinsen besteuern. Dadurch würde das Mitunternehmerkonzept durchbrochen. Vermittels eines Treaty Override (verbindliche Auslegung entgegen der Rechtsprechung) ist nach § 50d Abs. 10 Satz 1 EStG aber der Spezialitätsgrundsatz zu ignorieren und ausschließlich Art. 7 DBA-Polen anzuwenden, wobei die Sondervergütungen der Betriebsstätte zuzuordnen sind, die den korrespondierenden Aufwand trägt, also der KG-Betriebsstätte in Deutschland (§ 50d Abs. 10 Satz 3 erster Halbsatz EStG). Deutschland behält folglich ein vollumfängliches Besteuerungsrecht. Da auch Polen vollumfänglich besteuert (Steuersatz: 19 %) und dabei nur 5 % Steuern wegen Art. 11 Abs. 2 DBA-Polen anrechnet, verbleibt es i. H. v. 14 % bei einer Doppelbesteuerung. Hierauf hat der Gesetzgeber mit § 50d Abs. 10 Satz 5 EStG reagiert: Ausnahmsweise kann bei beschränkt steuerpflichtigen Mitunternehmern die Steuern, die in ihrem Ansässigkeitsstaat auf Sondervergütungen nicht angerechnet wurde, in Deutschland im Rahmen der vollumfänglichen Besteuerung angerechnet werden.



HINWEIS

Wenn Sie dieses Modul aufmerksam gelesen haben, dann fällt Ihnen auf, dass Beteiligungen im Sonderbetriebsvermögen II (an der Komplementär-GmbH oder an einer Vertriebsgesellschaft) abkommensrechtlich „tatsächlich“ i. S. d. Betriebsstättenvorbehalts (Art. 10 Abs. 4 DE-VHG) zur Betriebsstätte gehören und damit im Einklang mit dem Mitunternehmerkonzept im Staat der (Personengesellschafts-)Betriebsstätte besteuert werden können. Für Sonderbetriebsvermögen I wird diese tatsächliche Zugehörigkeit jedoch negiert. Dies mag erstaunen, ist aber ständige BFH-Rechtsprechung. Wegen dieser Unterschiede bedurfte es der Regelung in § 50d Abs. 10 EStG, der die Besteuerung nach dem Mitunternehmerkonzept wiederherstellt.

Ebenfalls um ein Nichtanwendungsgesetz handelt es sich bei **§ 50d Abs. 12 EStG**. Diese Vorschrift betrifft die BFH-Rechtsprechung zu Einkünften aus unselbständiger Arbeit i. S. v. Art. 14 DE-VHG und den für das Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates relevanten Veranlassungszusammenhang („dafür“).



► **Beispiel:**

Der unbeschränkt steuerpflichtige Hans Heckenhauer war über Jahrzehnte für einen deutschen Fußballclub tätig. Aufgrund von Eskapaden auf der Weihnachtsfeier wird unter diese Tätigkeit vonseiten des Arbeitgebers jedoch ein Schlussstrich gezogen. Da Hans Heckenhauer beste Kontakte zur Bild-„Zeitung“ pflegt, soll er durch eine stattliche Abfindung anlässlich seiner Vertragsbeendigung bei Laune gehalten werden. Die Abfindung wird im Juni 01 gezahlt. Hans Heckenhauer zieht bereits im Januar 01 nach Salzburg (Österreich).

► **Lösung:**

Ab Januar 01 ist Heckenhauer nach Art. 4 Abs. 1 DBA-Österreich in Österreich ansässig. Die Abfindungszahlung unterliegt nach § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d EStG der beschränkten Steuerpflicht. Zwar war Heckenhauer unselbständig in Deutschland tätig und Deutschland somit Tätigkeitsstaat i. S. d. Art. 15 Abs. 1 DBA-Österreich, allerdings erstreckt sich das Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates nur auf die „dafür“, also für die Tätigkeit gezahlten Vergütungen (Art. 15 Abs. 1 Satz 2 DBA-Österreich). Nach BFH-Rechtsprechung zählen hierzu nicht die Abfindungen anlässlich der Beendigung eines Dienstverhältnisses, weshalb nur dem Ansässigkeitsstaat das Besteuerungsrecht zustünde. Diese Rechtsprechung wird nun – abermals durch verbindliche Auslegung des DBA – dahingehend überschrieben, dass die Abfindungen als „für“ die frühere Arbeit geleistet gelten (§ 50d Abs. 12 Satz 1 EStG). Durch diese Fiktion wird das deutsche Besteuerungsrecht aufrechterhalten.

§ 8b Abs. 1 KStG sieht eine Freistellung von sog. Schachteldividenden vor, um eine wirtschaftliche Doppelbesteuerung zu vermeiden. Eine drohende Doppelbesteuerung liegt jedoch nicht vor, wenn auf Ebene der ausschüttenden Gesellschaft gar keine Belastung erfolgt, z. B., weil die Dividenden dort steuerlich abziehbar sind. Daher versagt § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG die Freistellung, wenn die Bezüge das Einkommen der ausschüttenden Gesellschaft gemindert haben. Dies gilt wegen § 8b Abs. 1 Satz 3 KStG auch für Fälle, in denen sich die Freistellung aus dem DBA ergibt.

► **Beispiel:**

Die deutsche D-GmbH ist zu 25 % an der französischen F-S. a. r. l. beteiligt. Die D-GmbH verkauft der F-S. a. r. l. Waren zu überhöhten Preisen. Frankreich nimmt jedoch keine Korrektur vor und behandelt die Einkaufspreise als steuerlich abziehbar.

► **Lösung:**

Aus deutscher Sicht liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung i. S. v. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG vor, die bei der D-GmbH zu Bezügen i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG führt. Nach Art. 9 Abs. 6 Satz 2 Buchst. a DBA-Frankreich liegen auch Dividenden i. S. d. DBA-Frankreich vor, selbst wenn Frankreich im konkreten Fall keine Gewinnausschüttung annimmt. Nach Art. 22 Abs. 1 Buchst. b DBA-Frankreich stellt Deutschland die Dividende frei. Da allerdings die Dividende auf Ebene der französischen Tochtergesellschaft den Gewinn gemindert hat (eine verhinderte Mehrung steht insoweit einer Minderung gleich), versagt § 8b Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Satz 3 KStG dieses abkommensrechtliche Schachtelprivileg. Die Dividenden werden folglich in Deutschland voll besteuert.

VIII. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 25 Minuten

Der Steuerpflichtige Sven Steuer hält sich dauerhaft im Ausland (Österreich) auf, wo er auch wohnt. Er unterliegt in Österreich der unbeschränkten Steuerpflicht. Aufgrund seiner inländischen Einkunftsquellen wird Sven Steuer jedes Jahr – unstreitig auch im Beurteilungszeitraum 01 – gemäß § 1 Abs. 3 EStG als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt.

Folgende Sachverhalte tragen sich in 01 zu:

- Sven Steuer hält Aktien an der Audi AG. Er erhält in 01 eine Dividende.
- Vor einigen Jahren (Spekulationsfrist von zehn Jahren noch nicht abgelaufen) erwarb Sven Steuer eine Eigentumswohnung in München, die er seither vermietet. Aus finanziellen Engpässen muss er die Wohnung am 1.1.01 verkaufen.
- Sven Steuer ist als Ingenieur im Angestelltenverhältnis tätig. Bis zum 30.6. übt er diese Beschäftigung in München für ein dort ansässiges Motorenwerk tätig. Nach Auflösung des Arbeitsvertrags, anlässlich dessen Beendigung ihm im August 01 eine großzügige Abfindung zugestanden wird, und einer dreimonatigen Urlaubspause nimmt Sven Steuer ab 1.10.01 eine Tätigkeit für ein in Österreich ansässiges Ingenieur-Büro, das nur in Österreich über Betriebsstätten verfügt, auf. Von 1.10. bis zum 31.12. ist Sven Steuer vollständig auf einem Projekt in Nürnberg, wo er für seinen österreichischen Arbeitgeber einen deutschen Mandanten technisch berät.
- Weitere Einkunftsquellen hat Sven Steuer nicht.

AUFGABE

Die oben genannten Sachverhalte sind für Sven Steuer hinsichtlich ihrer steuerlichen Auswirkungen im Inland nach deutscher Rechtslage (d. h. ohne Würdigung der unionsrechtlichen Grundverkehrsfreiheiten) zu beurteilen. Auf die Gewerbesteuer ist nicht einzugehen. Weder die Höhe der Einkünfte noch die Höhe der Steuerschuld sind zu ermitteln.

Freistellungsbescheinigungen liegen nicht vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 IStR 02 – v13107

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
Sven Steuer ist ausweislich des Sachverhalts fiktiv unbeschränkt steuerpflichtig nach § 1 Abs. 3 EStG. Die Steuerpflicht erstreckt sich dennoch nur auf seine „inländischen Einkünfte“ i. S. v. § 49 EStG. Sven Steuer ist eine „Person“ i. S. d. Abkommens, Art. 3 Abs. 1 Buchst. d DBA-Österreich, und nach Art. 4 Abs. 1 DBA-Österreich nur in Österreich ansässig, weil er dort unbeschränkt steuerpflichtig wegen seines Wohnsitzes und gewöhnlichen Aufenthalts ist. Die fiktiv unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland begründet keine hiesige Ansässigkeit. Sven Steuer ist persönlich abkommensberechtigt, Art. 1 DBA-Österreich, und die Einkommensteuer ist sachlich vom DBA erfasst, Art. 2 Abs. 3 Buchst. a Nr. 1 DBA-Österreich. Es besteht somit Abkommenschutz.	1	
Die Dividende gehört wegen § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG zu den inländischen Einkünften. Die Dividenden i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG unterliegen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG dem Kapitalertragsteuerabzug i. H. v. 25 % des Bruttoertrags, § 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 43a Abs. 2 Satz 1 EStG. Der Steuerabzug ist ungeachtet der fiktiven unbeschränkten Steuerpflicht vorzunehmen (§ 1 Abs. 3 Satz 6 EStG). Es handelt sich abkommensrechtlich um „Dividenden“ i. S. v. Art. 10 Abs. 3 DBA-Österreich, die nach Art. 10 Abs. 1 nur in Österreich, nach Art. 10 Abs. 2 Buchst. b DBA-Österreich in Höhe von 15 % auch in Deutschland besteuert werden können. Das deutsche Besteuerungsrecht wird folglich eingeschränkt. Trotz der abkommensrechtlichen Beschränkungen ist der Steuerabzug vorzunehmen, § 50c Abs. 1 Satz 1 EStG. Sven Steuer muss seinen Entlastungsanspruch im Rahmen der Veranlagung als fiktiv unbeschränkt Steuerpflichtiger geltend machen, die er nach § 32d Abs. 4 EStG beantragen kann (§ 50 Abs. 2 EStG greift nicht).	2	
Sven Steuer erzielt aus der Veräußerung sonstige Einkünfte i. S. v. § 22 Nr. 2 EStG i. V. m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, weil zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als zehn Jahre liegen. Es handelt sich um inländische Einkünfte i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b EStG. Abkommensrechtlich liegt unbewegliches Vermögen i. S. v. Art. 6 Abs. 2 DBA-Österreich vor, weil aus Sicht Deutschlands als Belegenheitsstaat eine Eigentumswohnung zum unbeweglichen Vermögen gehört. Die Besteuerung kann nach Art. 13 Abs. 1 DBA-Österreich vollumfänglich in Deutschland besteuert werden.	1	

Als Arbeitnehmer steht Sven Steuer in einem Dienstverhältnis i. S. v. § 1 Abs. 2 LStDV und erzielt Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Es handelt sich sowohl bei den aus der Tätigkeit für den deutschen Arbeitgeber als auch bei den aus der Tätigkeit für den österreichischen Arbeitgeber erzielten Einkünfte um inländische Einkünfte i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a EStG. Die Abfindungszahlung führt nach § 24 Nr. 1 EStG zu nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit i. S. v. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG und zu inländischen Einkünften i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d EStG. Die Einkünfte aus der Tätigkeit für den deutschen Arbeitgeber können aufgrund der Tätigkeitsausübung in Deutschland besteuert werden, soweit sie „dafür“ gezahlt werden Art. 15 Abs. 1 Satz 2 DBA-Österreich. Dies gilt für den laufenden Arbeitslohn bis Ende Juni und wegen § 50d Abs. 12 Satz 1 EStG auch für die Abfindungszahlung. Die 183-Tage-Klausel nach Art. 15 Abs. 2 DBA-Österreich ist nicht anwendbar, weil die Vergütungen von einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber gezahlt werden (Buchst. b). Die Einkünfte aus der Tätigkeit für den österreichischen Arbeitgeber können grundsätzlich aufgrund der Tätigkeitsausübung in Nürnberg ebenfalls in Deutschland besteuert werden, Art. 15 Abs. 1 DBA-Österreich. Wiederum greift vorliegend die Ausnahme der 183-Tage-Klausel nicht ein, weil sich Sven Steuer im Kalenderjahr insgesamt mehr als 183 Tage in Deutschland aufhält und Art. 15 Abs. 2 Buchst. a DBA-Österreich nicht erfüllt ist. Deutschland darf nach dem DBA besteuern.	3	
GESAMTPUNKTZAHL	7	



2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 15 Minuten

Die österreichische Ö-GmbH hat Sitz und Geschäftsleitung in Wien. Anteilseigner sind zu je 50 % Sven Steuer (aus Übungsfall 1) sowie die in Brasilien (kein DBA) wohnhafte natürliche Person Paulo Sergio. Die Gesellschaft schüttet im Beurteilungszeitraum keine Dividende aus.

Die GmbH erzielt Einkünfte aus selbst erstellten immateriellen Wirtschaftsgütern, die sie fremden Dritte überlasst. Sämtliche Lizenznehmer sind in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Sowohl die Geschäftsleitung als auch die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten werden durch eigenes Personal der GmbH in deren Geschäftsräumen in Österreich ausgeübt.

AUFGABE

Der oben genannte Sachverhalt ist für die GmbH hinsichtlich ihrer steuerlichen Auswirkungen im Inland nach deutscher Rechtslage (d. h. ohne Würdigung der unionsrechtlichen Grundverkehrsfreiheiten) zu beurteilen. Auf die Gewerbesteuer ist nicht einzugehen. Weder die Höhe der Einkünfte noch die Höhe der Steuerschuld sind zu ermitteln.

Freistellungsbescheinigungen liegen nicht vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 IStR 02 – v13171

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Die GmbH ist mangels eines Orts der Geschäftsleitung (§ 10 AO) und Sitzes (§ 11 AO) im Inland nicht unbeschränkt steuerpflichtig nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG. Sie ist aber nach § 2 Nr. 1 KStG i. V. m. § 49 EStG i. V. m. § 8 Abs. 1 KStG beschränkt steuerpflichtig, soweit sie inländische Einkünfte erzielt. Die GmbH ist nach Art. 4 Abs. 1 DBA-Österreich in Österreich ansässig, weil sie dort aufgrund ihres Sitzes und ihrer Geschäftsleitung unbeschränkt steuerpflichtig ist.	1	
Die GmbH erzielt wegen § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Satz 4 EStG aus der Überlassung des Patents Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Es handelt sich wegen § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Satz 1 Buchst. a EStG auch um inländische, also beschränkt steuerpflichtige Einkünfte, weil eine Verwertung im Inland erfolgt. Die Einkünfte unterliegen dem Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG in Höhe von 15 % des Bruttobetrags, § 50a Abs. 3 Satz 1 EStG. Die Voraussetzungen des § 50g EStG sind nicht erfüllt, weil es sich nicht um Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen handelt, § 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchst. b EStG. Der Steuerabzug hat Abgeltungswirkung, § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG. Abkommensrechtlich liegen Lizenzgebühren i. S. v. Art. 12 Abs. 1 DBA-Österreich vor, die ausschließlich im Ansässigkeitsstaat, also Österreich besteuert werden können. Das deutsche Besteuerungsrecht wird also abkommensrechtlich ausgeschlossen. Ungeachtet dessen ist wegen § 50c Abs. 1 Satz 1 EStG der Steuerabzug vorzunehmen und eine Erstattung nach § 50c Abs. 3 EStG zu beantragen.	2	
Der Anspruch auf Entlastung im Erstattungsverfahren steht unter dem Vorbehalt des § 50d Abs. 3 EStG. Die Voraussetzungen für eine Versagung des Entlastungsanspruchs sind jedoch nicht erfüllt. Zwar stehen nur zu 50 % den an der GmbH beteiligten Personen dieselben Entlastungsansprüche zu, nämlich Sven Steuer, der ebenfalls eine Entlastung nach Art. 12 Abs. 1 DBA-Österreich begehren könnte. Soweit Paulo Sergio aus Brasilien an der GmbH beteiligt ist, besteht zwar keine persönliche Entlastungsberechtigung. Infolge der durch die GmbH ausgeübte Forschungs- und Entwicklung übt die Gesellschaft jedoch eine Wirtschaftstätigkeit aus, mit der die Einkunftsquelle (Rechte) in wesentlichem Zusammenhang stehen. Somit ist die sachliche Entlastungsberechtigung erfüllt.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	4	



3. Übungsfall 3

Bearbeitungszeit ca. 45 Minuten

Der Steuerpflichtige Brüno ist Franzose, der mit seiner Familie in Straßburg (Frankreich) ein prächtiges Haus bewohnt. Um dieses Haus zu finanzieren ist, ist Brüno seit Jahren für eine österreichische Hotelkette in deren Salzburger Dependence tätig, wo er als Konditor Schokoladentorten „zaubert“. Wochentags ist er daher von seiner in Frankreich verweilenden Familie getrennt. Da Brüno schon immer in Bayern leben wollte und sein Salzburger Arbeitsplatz nur 2 km von der deutschen Grenze entfernt liegt, entschied er sich, täglich aus Deutschland zur Arbeit zu pendeln. In Freilassing, keine 5 km von der deutsch-österreichischen Grenze entfernt, unterhält Brüno eine Mietwohnung. Die Wochenenden verbringt er mit seiner Familie in Frankreich. Von seinem französischen Steuerberater weiß er, dass nach dem DBA zwischen Frankreich und Österreich das Besteuerungsrecht bei Österreich liegt.

Die zahlreichen Touristen aus China, die in Salzburg Brünos Torten probieren, sind hellauf begeistert. Um noch mehr Geld zu scheffeln, macht sich Brüno selbständig und bietet in China Dienstleistungen im Bereich „Backkunst“ an, indem er eine chinesische Koch- und Backschule berät. Da seine Frau ihm nicht erlaubt, selbst nach China zu reisen, kauft Brüno seinen langjährigen Küchengehilfen Pierre aus dessen Arbeitsvertrag mit dem Hotel heraus und schickt ihn als seinen eigenen Angestellten nach China. Von April 01 bis Ende Dezember 01 erbringt Pierre im Auftrag und unter Anweisung Brünos Dienstleistungen an die chinesische Koch- und Backschule. Eigene Geschäftsräume unterhält Brüno in China nicht.

Bei den aus den Dienstleistungen erzielten Erträge handelt es sich nicht um solche, die aktiv i. S. v. § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AStG sind.

AUFGABE

Beurteilen Sie die steuerlichen Folgen der dargestellten Sachverhalte. Auf die Gewerbesteuer ist nicht einzugehen. Weder die Höhe der Einkünfte noch die Höhe der Steuerschuld sind zu ermitteln.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 3 IStR 02 – v13236

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 3	Punkte	
	Soll	Ist
Brüno unterhält einen Wohnsitz in Deutschland, § 8 AO, und ist daher gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 EStG unbeschränkt steuerpflichtig. Er unterliegt dem Welteinkommensprinzip, H 1a EStH „Allgemeines“. Brüno erzielt Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Da es sich bei den Einkünften um ausländische Einkünfte i. S. v. § 34d Nr. 5 EStG handelt, kommt vorbehaltlich der DBA-Anwendung eine Anrechnung der österreichischen Steuern in Frage.	1	
DBA-Österreich: Brüno ist nach Art. 4 Abs. 1 DBA-Österreich in Deutschland ansässig, weil er in Deutschland aufgrund eines Wohnsitzes unbeschränkt steuerpflichtig ist. Die Einkommensteuer ist auch sachlich vom DBA erfasst, Art. 2 Abs. 3 Buchst. a Nr. 1 DBA-Österreich. Es besteht somit Abkommenschutz. Aufgrund seiner Tätigkeit als Angestellter erzielt Brüno Einkünfte aus unselbständiger Arbeit i. S. v. Art. 15 DBA-Österreich. Nach Art. 15 Abs. 1 DBA-Österreich steht Österreich als Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht zu. Allerdings greift vorliegend die Ausnahmeregelung für Grenzgänger nach Art. 15 Abs. 6 DBA-Österreich, weil sich sowohl seine Wohnung in Freilassing als auch sein Arbeitsort in Salzburg in Grenznähe (vgl. Nr. 8 des Protokolls: jeweils 30 km von der Grenze) befinden und er täglich an einen Wohnsitz zurückkehrt. Es gilt folglich nicht das Tätigkeitsortprinzip, sondern Deutschland darf als Ansässigkeitsstaat besteuern.	1	
DBA-Frankreich: Brüno ist nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a DBA-Frankreich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ansässig, weil er sowohl in Deutschland als auch in Frankreich aufgrund eines Wohnsitzes unbeschränkt steuerpflichtig ist. Die Einkommensteuer ist auch sachlich vom DBA erfasst, Art. 2 Abs. 3 Buchst. a Nr. 2 DBA-Frankreich. Es besteht somit Abkommenschutz.	1	
Nach Art. 2 Abs. 3 Buchst. b Doppelbuchst. aa DBA-Frankreich gilt jedoch nur Frankreich als Ansässigkeitsstaat, weil aufgrund des dortigen Familienwohnsitzes die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen Brünos zu Frankreich bestehen.	1	
Brüno erzielt Einkünfte aus unselbständiger Arbeit. Diese können mangels Tätigkeitsausübung in Deutschland nur im Ansässigkeitsstaat (also Frankreich) besteuert werden, Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich/Art. 18 DBA-Frankreich. Die 183-Tage-Regel (Art. 13 Abs. 4 DBA-Frankreich) und die Grenzgängerregelung (Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich) sind nicht anwendbar. Das deutsche Besteuerungsrecht wird ausgeschlossen. Es bleibt bei der Anwendung des Progressionsvorbehalts, § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG.	1	



>>> HINWEIS <i>Das DBA-Frankreich unterscheidet sich insoweit vom OECD-MA und der DE-VHG als in Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich kein grundsätzliches Besteuerungsrecht für den Ansässigkeitsstaat aufgestellt wird, sondern jeder Staat (nur) dann besteuern darf, wenn die Tätigkeit dort ausgeübt wird. Da die Tätigkeit vorliegend auch nicht in Frankreich ausgeübt wird, läge diese Bedingung für keinen der beiden Vertragsstaaten vor. Es handelt sich daher um Einkünfte, die in keinem vorherigen DBA-Artikel behandelt sind und die nach Art. 18 DBA-Frankreich als „andere Einkünfte“ nur im Ansässigkeitsstaat besteuert werden können.</i>		
Laut Aufgabenstellung können die Einkünfte nach dem DBA zwischen Frankreich und Österreich nur in Österreich (als Tätigkeitsstaat) besteuert werden. Sofern Frankreich und Österreich sich an ihre abkommensrechtlichen Verpflichtungen halten, bleiben die Einkünfte somit in sämtlichen Staaten unversteuert. Den gemäß § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG zu erbringenden Nachweis kann Brüno jedoch führen, weil Frankreich durch das DBA-Österreich auf sein Besteuerungsrecht verzichtet (vgl. auch BMF, Schreiben v. 21.7.2005, BStBl 2005 I S. 821, Beck- Steuererlasse § 50d/2 zu Nr. 1, Tz. 2.2: völkerrechtlicher Vertrag kann Verzicht darstellen). Die Freistellung bleibt somit aufrechterhalten.	1	
Bei der Erbringung von Dienstleistungen handelt es sich um eine gewerbliche Tätigkeit i. S. v. § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Die im Ausland erzielten Einkünfte sind im Rahmen des Welteinkommens im Inland zu erfassen. Die Vermeidung der Doppelbesteuerung richtet sich nach dem DBA, § 34c Abs. 6 Satz 1 EStG.	1	
Nach dem DBA ist Brüno eine „Person“, Art. 3 Abs. 1 Buchst. d DBA-China, die aufgrund ihres deutschen Wohnsitzes in Deutschland ansässig ist, Art. 4 Abs. 1 DBA-China. Die Einkommensteuer ist auch sachlich vom DBA erfasst, Art. 2 Abs. 3 Buchst. b (i) DBA-China. Es besteht somit Abkommensschutz.	1	
Es handelt sich um Unternehmensgewinne i. S. v. Art. 7 DBA-China, wobei das Unternehmen von Brüno betrieben wird und damit als Unternehmen des Vertragsstaats Deutschland anzusehen ist, Art. 3 Abs. 1 Buchst. f DBA-China. Nach Art. 7 Abs. 1 DBA-China darf grundsätzlich nur Deutschland besteuern, wobei China auch besteuern darf, wenn dort eine Betriebsstätte gegeben ist. Zwar unterhält Brünos Unternehmen in China keine eigenen Geschäftsräume und damit keine Betriebsstätte nach Art. 5 Abs. 1 DBA-China, nach Art. 5 Abs. 3 Buchst. b DBA-China gilt aber auch die Erbringung von Dienstleistungen von mehr als 183 Tagen innerhalb eines Zeitraums für ein Vorhaben als Betriebsstätte (sog. Dienstleistungsbetriebsstätte). Diese Voraussetzungen sind erfüllt, weshalb China den Betriebsstättengewinn besteuern darf.	1	
Deutschland stellt den Betriebsstättengewinn grundsätzlich nach Art. 23 Abs. 2 Buchst. a DBA-China unter Progressionsvorbehalt frei. Da jedoch laut Aufgabenstellung die Einkünfte nicht solche i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AStG, sondern passive Dienstleistungen, sind, kommt es aufgrund der Aktivitätsklausel in Art. 23 Abs. 2 Buchst. c DBA-China zu einem Wechsel zur Anrechnungsmethode. Die Freistellung wird versagt. Eine Anrechnung erfolgt wegen § 34c Abs. 6 Satz 2 EStG wegen des DBA ungeachtet der Tatsache, dass keine ausländischen Einkünfte vorliegen.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	11	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!